Sommaire de l'article

Parution: juillet 2023

La valorisation économique et fiscale des droits démembrés et la structuration juridique de l'opération

500

Comme tout actif inscrit au bilan d'une entreprise, l'usufruit et la nue-propriété doivent être évalués pour leur coût d'acquisition (c. com. art. L. 123-18 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L123-18&idspad=LEGIARTI000006219310) et PCG art. 321-1).

Or, pas plus que pour l'évaluation des biens en pleine propriété, il n'existe de méthode légale d'évaluation des droits démembrés.

La loi a toutefois prévu une méthode obligatoire et forfaitaire d'évaluation des droits démembrés destinée à fixer l'assiette de certains impôts (droits de mutation à titre gratuit, droit d'enregistrement et taxe de publicité foncière – CGI art. 669 et plus-values des particuliers – art. 669 du CGI par renvoi de l'article 74 SE de l'annexe II du même code). Le barème fiscal est fondé sur une méthode simplifiée de cash-flow actualisé *(sur les fondements de la méthode d'évaluation fiscale V° R. Julliany : De la réforme des droits d'enregistrement au point de vue de la constitution d'usufruit, Thèse Paris 1908* ; E. Maguero : *Traité alphabétique des droits d'enregistrement de timbre et d'hypothèque* 2e éd. *Usufruit et Nue-propriété* pp. 436 et s.) dont les paramètres ne résultent pas des biens en cause, mais sont arbitrairement fixés par l'administration (espérance de vie résultant des tables de mortalité en vigueur lors du vote de la loi de finances pour 2004 et taux de rendement forfaitairement fixé à 3 % pour les usufruits viagers et 2,3 % pour les usufruits à durée fixe). Il en résulte donc des résultats erronés au regard des valeurs vénales. Il faut donc retenir que le barème fiscal n'est qu'une règle de détermination de l'assiette de l'impôt : elle n'a pas pour fonction de donner la valeur vénale des actifs (M. Iwanesko et P. Julien-Saint-Amand : CGI art. 669 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=669&idspad=LEGIARTI000006310173), BF 01/2005).

Chapitre I - La détermination de la valeur des droits démembrés

501

Faute de méthode légale obligatoire, la jurisprudence considère depuis le XIXe siècle que les droits démembrés doivent être évalués selon leur valeur vénale. En effet, dès 1866 (cass. civ. 28 mars 1866, Berard de Bonnières - Petit, S. 1866.1.396), la Cour de cassation eut l'occasion de préciser :

« Sur les bases à adopter pour l'évaluation de l'usufruit :

Attendu que si l'on prend pour règle de l'évaluation de l'usufruit la moyenne adoptée par la loi du 22 frimaire de l'an VII pour la perception des droits d'enregistrement et si en conséquence on évalue le plus souvent la valeur de l'usufruit à la moitié de la propriété, rien n'empêche aux tribunaux une évaluation résultant de toutes les circonstances qui peuvent faire varier la valeur de l'usufruit et spécialement de la circonstance importante de l'âge de l'usufruitier... ».

...

« Attendu, ...qu'aucune règle générale sur la manière d'évaluer l'usufruit n'est établie audit code (NDA : Code civil) ; que par cela même, l'appréciation a été laissée à la prudence et à la sagesse du juge du fonds et que dès lors, l'arrêt attaqué a pu, sans violer aucune disposition de la loi, décider qu'en raison des circonstances particulières de la cause, l'usufruit, dans l'espèce devait être évalué au quart de la propriété ».

Plus récemment, elle a rappelé (cass. civ., 1re, 25 février 1997, BC I n° 76) que la valeur des droits démembrés est constituée par leur valeur vénale : *« Mais attendu qu'en décidant exactement que la répartition du prix entre les venderesses, usufruitière et nues-propriétaires des actions, devait être proportionnelle à la valeur comparative de l'usufruit et de la nue-propriété et en retenant souverainement que l'évaluation de l'usufruit devait se faire en tenant compte de l'âge de l'usufruitière et du revenu net qu'elle pouvait espérer obtenir des actions vendues, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile et n'a pas violé le texte susvisé dont l'application ne s'impose qu'en matière fiscale ; qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est donc fondé... ».*

La pratique utilise majoritairement la méthode du cash-flow actualisé pour l'évaluation des droits démembrés (ce mode d'évaluation étant également celui retenu par l'administration pour la détermination du barème fiscal, voir § 523 (20190730150406293.html#523)).

La doctrine majoritaire (voir notamment J. Aulagnier : Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine, éd. Maxima) s'accorde aujourd'hui sur deux points :

-les droits démembrés doivent être calculés en utilisant la méthode du cash-flow actualisé. Le taux d'actualisation utilisé étant le taux de rentabilité de la pleine propriété du bien démembré net de charges usufructuaires. Cette méthode repose sur un principe simple, largement partagé par les économistes depuis Irving Fischer que la valeur d'une chose ne vaut que par la somme des flux financiers que cette chose produit ou est susceptible de produire durant son existence (J. Aulagnier : Démembrement de propriété : stratégies actuelles et perspectives, Droit et Patrimoine 1999, n° 76).

-la valeur de la pleine propriété est égale à la somme algébrique de la nue-propriété et de l'usufruit (contra : B. Mailley : Usufruit, nue-propriété et viager : méthodes d'estimation, AJPI, 10 avril 1985).

Si l'équation U + NP = PP est aujourd'hui largement admise, l'approche contraire retenue par Maître Bernard Mailley mérite qu'on s'y attarde.

Dans la « méthode Mailley », la valeur de la pleine propriété ne correspond pas à l'addition de la nue-propriété et de l'usufruit. La nue-propriété serait une propriété grevée de la charge constituée par l'usufruit. Elle doit être fixée sur la base de données objectives relatives au bien démembrée exclusivement. L'usufruit quant à lui doit être évalué de façon subjective, c'est-à-dire déterminé par rapport au bien mais aussi en fonction du titulaire de ce droit.

Ainsi, le taux de rendement de référence tiendra compte de données objectives (revenus net de charges générés par le bien et taux de rendement) et de données subjectives (situation fiscale de l'usufruitier, risques locatifs, politique de gestion...). Par ailleurs, le taux de rentabilité pris en compte ne sera pas forcément identique à celui retenu pour le calcul de la nue-propriété (Pierre Cénac, Michel Gouillard, Arnaud Jaffrin, L'usufruit locatif social, Les Éditions de l'Immobilier Social).

Pour Jean Aulagnier, au contraire, l'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété doit se faire à partir des mêmes critères et notamment d'un taux de rentabilité objectif tenant compte des revenus générés par le bien et des charges usufructuaires. La situation particulière de l'usufruitier, et notamment fiscale ne sera alors pas prise en compte. Cette analyse est également partagée par Pierre Fernoux et par tous les auteurs de cet ouvrage. Nous y reviendrons en détail (voir § 508 (20190730150406293.html#508)).

I. Les paramètres du calcul

502

La méthode privilégiée tant par l'administration que par le juge administratif est la méthode des comparables. Il convient de rechercher le prix retenu par les parties dans des transactions comparables. Très utile lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur de la pleine propriété d'un immeuble, cette méthode n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de déterminer la valeur de l'usufruit d'un immeuble ou, plus compliqué encore, la valeur de l'usufruit de parts d'une société immobilière, faute de comparables.

Le juge administratif précise qu'en l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, ce qui est systématiquement le cas en la matière, l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date où la cession est intervenue.

Cette précision a le mérite de donner la possibilité d'utiliser d'autres méthodes d'évaluation dès lors que celles-ci permettent d'estimer la valeur qu'un acquéreur serait prêt à consentir à un vendeur (prix maximal) ou qu'un vendeur accepterait d'accorder à un acheteur potentiel (prix minimal). La valeur vénale, c'est-à-dire le prix final, se trouve entre ce maximum et ce minimum, mais n'est jamais simple à atteindre en l'absence de marché. En outre, le prix convenu entre les parties dans une cession d'usufruit peut se retrouver être soumis au contrôle du juge administratif puisque les parties sont rarement indépendantes, ce qui laisse penser qu'une libéralité, dans un sens ou dans un autre, est toujours possible.

L'approche retenue par les acteurs économiques pour déterminer la valeur d'un actif est identique à celle du juge de l'impôt avec cependant deux approches privilégiées : les comparables, appliqués en général à travers des multiples d'un agrégat financier et la méthode consistant à actualiser les cash-flows prévisionnels, dénommée méthode DCF (Discounted Cash-Flows). Pour un investisseur en capital, la seule méthode pertinente est celle des DCF. « En termes simples, la valeur actuelle d'une entreprise est la somme de tout l'argent qu'elle gagnera dans le futur. Pour correctement valoriser une entreprise, il faut aussi actualiser ces flux de liquidités futurs à leur valeur présente, car une somme d'argent donnée vaut aujourd'hui davantage que la même somme dans le futur », écrit Peter Thiel, célèbre investisseur de la Silicon Valey ayant investi dans Facebook, SpaceX et LinkedIn (P. Thiel, De zéro à un : JC Lattès, 2016).

La valeur patrimoniale est rarement utilisée compte tenu de ses nombreux défauts :

-elle ne représente pas la valeur liquidative de l'entreprise et ne donne donc pas une valeur plancher puisque les comptes doivent être arrêtés selon le principe comptable de la continuité d'exploitation ;

-elle ne valorise pas le goodwill qui doit être appréhendé par une approche complémentaire basée sur la rentabilité, ce qui revient à utiliser de manière détournée l'approche DCF ;

-les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Si l'on pousse l'analyse et la réflexion, on peut même s'interroger sur le fait de savoir si la méthode des comparables et des multiples n'est pas en réalité bien plus un raccourci qu'une véritable méthode en elle-même. Cette technique permet de faire l'impasse sur la méthode DCF qui oblige à établir un prévisionnel sur une longue période de l'ensemble des flux attendus d'une entreprise, exercice complexe et délicat. La méthode des comparables sous-entend en vérité que ce travail a déjà été fait par le marché et qu'une entreprise agissant sur le même secteur, avec le même taux de croissance est susceptible de générer les mêmes flux et donc d'avoir la même valorisation, au taux implicite accepté par le marché.

II. La valorisation de l'usufruit

503

Ainsi, la méthode des DCF est la seule qui permette de donner à une société, quelle que soit sa singularité, une valeur représentant la somme actualisée de « tout l'argent qu'elle gagnera dans le futur ». Comme le dit Maurice Allais, « la valeur économique d'un bien est la valeur actuelle de ses produits futurs » (citée in J. Aulagnier, Usufruit et nue-propriété dans la gestion de patrimoine, Maxima, 2e édition 2001), et c'est bien cette seule valeur qui permet d'obtenir « un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ».

A. La valorisation de l'usufruit d'un bien immobilier : la méthode DCF

504

La méthode DCF, dans sa version abrégée, est également celle qui est communément appliquée en matière immobilière lorsqu'on valorise un bien immobilier à partir d'un taux de rendement.

En effet, si un bien génère un revenu de 100 et que le taux de rendement est de 5 %, l'actualisation à l'infini d'un revenu de 100 au taux de 5 % équivaut à diviser 100 par 0,05 pour donner la valeur de la pleine propriété de l'immeuble, soit 2 000.

À l'aide d'un tableur, si on positionne un revenu de 100 sur une durée de 100 ans et qu'on recherche la valeur actuelle nette (VAN) de ce flux au taux de 5 %, on obtient 1 984,79, soit une approximation (les calculs ayant été faits sur 100 ans et non sur l'infini) de 99,3 %. Cette petite précision méthodologique sera utile pour bien comprendre les différents calculs qui vont suivre. Elle consiste ainsi à considérer qu'en actualisant un revenu sur une durée de 100 ans, on obtient la valeur de la pleine propriété, ce qui est vrai à 0,7 % près.

En procédant de la sorte, par une actualisation du flux sur une très longue période (100 ans), on peut faire abstraction de la valeur terminale. En effet, même en imaginant une valeur terminale de 4 000 dans 100 ans (n'oublions pas que le flux de 100 n'a pas été indexé, ce qui traduit une valorisation de la valeur terminale sur un taux de rendement de 2,5 %), la valeur de la pleine propriété passe à 2 014,45, soit 100,7 % de la valeur réelle de la pleine propriété. Retenons donc que l'actualisation d'un flux sur 100 ans donne une approximation suffisante de la valeur de la pleine propriété, à 0,7 % près.

505

Mais que se passe-t-il si on décide d'indexer le revenu, comme cela est usuellement le cas dans tout bail ?

Le Conseil d'État (CE, 8e et 3e ch., 24 octobre 2018, n° 412322) (voir annexe A11) a apporté fin 2018 une réponse claire et d'une portée plus large qu'une rapide lecture pourrait laisser penser en nous éclairant sur la bonne méthode à retenir.

Le 4 septembre 2008, la SCI Sacajisme, soumise à l'IS, et la SCI Sacaj, soumise au régime fiscal des sociétés de personnes, ont acquis respectivement l'usufruit pour une durée de 22 ans et la nue-propriété d'un immeuble d'une valeur totale de 730 000 €. L'administration a estimé que le prix de 645 000 € pour acquérir l'usufruit excédait de 145 000 € la valeur de celui-ci et que l'excédent constituait une libéralité accordée à la SCI Sacaj, nu-propriétaire.

Le tribunal administratif de Strasbourg (TA Strasbourg 29 septembre 2015, n° 1201626), puis la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2e ch., 11 mai 2017, n° 15NC02356 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NC&annee=15&numero=02356&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/34/72/35/CETATEXT000034723578.xml&dat 05-11)) ont débouté l'administration de ses demandes, considérant que la méthode du contribuable était la bonne. Cette dernière consistait à actualiser les flux de revenus futurs, au taux de rendement du bien, soit 5,26 %, sur la durée du démembrement, soit 22 ans, en tenant compte d'une indexation du loyer de 3 % par an.

On constate en effet que l'actualisation sur 22 ans au taux de 5,26 % d'un flux de 38 398 € (5,26 % de 730 000 €), en progression de 3 % par an, permet d'obtenir une valeur de l'usufruit de 645 064 €, montant arrondi par le contribuable à 645 000 €.

L'administration, de son côté, estimait qu'il fallait exclure le taux d'indexation du loyer de 3 % du calcul, ce qui consistait à actualiser un revenu de 38 398 € pendant 22 ans au taux de 5,26 %, soit un montant de 493 664 € arrondi par l'administration à 500 000 €.

L'écart entre les deux méthodes est bien de 145 000 €. Ne pas tenir compte de l'inflation n'est pas réaliste, et c'est la raison qui a ainsi conduit le tribunal administratif de Strasbourg et la cour administrative d'appel de Nancy à suivre le raisonnement du contribuable. Mais la méthode retenue par ce dernier est-elle pour autant pertinente en ce qu'elle donne un partage équitable de la valeur de la pleine propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ?

Le Conseil d'État précise d'abord dans un attendu de principe la règle applicable en la matière :

« En l'absence de toute transaction ou de transaction équivalente, l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date ou l'acquisition est intervenue. Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode d'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne (TRI) de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire. »

Or, le contribuable, en prenant en compte l'inflation dans ses prévisions de revenus locatifs tout en appliquant un taux d'actualisation ne prenant pas en compte l'inflation, retient en réalité des termes de comparaison « non homogènes » qui conduisent « par suite à une rentabilité interne de l'investissement (un TRI) déséquilibrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et à un partage inexact, à la date de la cession, de la valeur en pleine propriété de l'immeuble entre celle de l'usufruitier et celle de la nue-propriété, cette méthode erronée ayant pour conséquence que la somme de la valeur ainsi déterminée de l'usufruit et de la valeur vénale de la nue-propriété soit supérieure au prix d'acquisition de la pleine propriété ».

Le Conseil d'État nous affirme ainsi :

-que l'équation U + NP = PP est indépassable ;

-et que seule l'utilisation du TRI permet de respecter cette égalité.

Pour en revenir au cas d'espèce de Sacaj et Sacajisme, le contribuable avait le choix en réalité entre deux méthodes : actualiser les flux au taux de 5,26 % sans inflation (le taux de rendement du bien, 5,26 %, étant égal au TRI de l'investissement en l'absence d'inflation) ou actualiser les flux avec une inflation de 3 % du loyer, mais au taux interne de rentabilité de l'investissement qui ressort, compte tenu de l'inflation du loyer, à 8,26 %... Dans ces deux solutions, l'actualisation se fait au taux interne de rentabilité, égal au taux de rendement du bien si le revenu ne progresse pas, supérieur à celui-ci, si le revenu est inflaté.

En effet, si on actualise sur 100 ans un flux de 38 398 € sans inflation au taux de 5,26 %, on obtient une valeur de la pleine propriété de 725 665 € (99,4 % de la valeur de la pleine propriété acquise 730 000 €). L'actualisation de la même somme inflatée de 3 % par an au taux de 5,26 % donne une valeur de la pleine propriété de 1 505 122 € ce qui, à l'évidence, n'est pas la bonne valeur ! Le conseil d'État a donc parfaitement raison en considérant cette méthode comme « erronée ». Pour obtenir une valeur de la pleine propriété de 730 000 € en tenant compte de l'inflation de 3 % du loyer, il faut actualiser les flux au taux interne de rentabilité de 8,26 %.

La première méthode (5,26 % de taux d'actualisation sans inflation du loyer) donne, on l'a vu, une valeur de l'usufruit sur 22 ans de 493 664 €. La seconde méthode (8,26 % de taux d'actualisation avec une inflation du loyer de 3 % par an) donne une valeur de l'usufruit sur 22 ans de 486 187 €, soit une valeur très proche de celle découlant de la première méthode (1,5 % d'écart). En d'autres termes, peu importe la méthode retenue puisque les résultats sont quasi identiques lorsqu'on actualise les flux au TRI.

Seules ces deux méthodes permettent un partage équilibré entre l'usufruitier et le nu-propriétaire de la valeur de la pleine propriété en offrant à chacun d'eux un taux de rendement interne de l'investissement identique, condition indispensable pour conserver l'équilibre U + NP = PP.

En définitive, et cet apport est déterminant, le taux à retenir pour évaluer la valeur d'un usufruit doit être le taux interne de l'investissement et celui-ci doit être identique pour l'usufruitier et le nu-propriétaire. Ni le taux de rentabilité du bien, méthode qui n'est valable en pratique qu'en l'absence d'indexation du loyer, ce qui reste un cas particulier, ni un taux externe (construit sur la base d'un taux sans risque majoré d'une prime de risque dépendant des marchés financiers) n'est acceptable dès lors qu'ils conduiront à un partage de la valeur entre l'usufruitier et le nu-propriétaire déséquilibré, et donc au bénéfice ou au détriment de l'un ou de l'autre.

Tirant les conséquences de la décision du Conseil d'État (op.cit.) la Cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2e ch. - formation à 3, 14 mai 2019, n° 18NC00107 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NC&annee=18&numero=00107&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/38/48/66/CETATEXT000038486634.xml&dat 05-14)) (voir annexe A16) a ainsi débouté l'administration lorsqu'elle utilise une « méthode [qui] repose sur des termes de calcul non homogènes, comme le fait valoir la société requérante, dès lors que l'administration a actualisé la valeur de la pleine propriété, à la date du terme du démembrement, à partir du taux de revalorisation des loyers qui est un taux constant ne tenant pas compte de l'évolution du prix de l'immobilier dans ce secteur géographique, tout en conservant au dénominateur un taux de rendement des flux futurs de l'usufruitier, qui intègre une évaluation de l'évolution des loyers pendant la durée de l'usufruit au regard du risque financier de l'investissement immobilier. La méthode de l'administration conduit par suite à une rentabilité interne de l'investissement déséquilibrée entre l'usufruitier et le nu-propriétaire et à un partage inexact, à la date de la cession, de la valeur en pleine propriété de l'immeuble entre celle de l'usufruit et celle de la nue-propriété, cette méthode erronée ayant pour conséquence que la somme de la valeur ainsi déterminée de l'usufruit et de la valeur vénale de la nue-propriété soit supérieure au prix d'acquisition de la pleine propriété. ».

Relevons notamment que dans cette affaire, le contribuable avait « déterminé un taux de rendement, compris entre 8, 5 et 18 % selon les immeubles, qui a été appliqué, dans le cadre de la méthode du cash-flow actualisé, aux flux futurs attendus par l'usufruitier ». En l'occurrence, « ce taux de rendement, qui n'est pas remis en cause par l'administration, prend en considération, selon la société requérante, le risque financier lié notamment à l'aléa de la location d'un immeuble commercial dans le secteur géographique où se situent les biens en cause ». Comme on l'a dit, cette méthode doit être approuvée.

506

Pourtant, cette approche n'est pas partagée par tous.

Pierre Carcelero (FRFS 31/19, 4-7-19, « Est-il si complexe d'évaluer des droits démembrés ? ») considère à l'inverse que cet équilibre, la recherche d'un taux de rendement identique pour l'usufruitier et le nu-propriétaire, conduit « à comparer les méthodes d'évaluation de l'usufruit et de la nue-propriété pour apprécier une éventuelle survalorisation du prix de l'usufruit ». Or, pour lui, « il n'existe à notre connaissance, aucun principe selon lequel des partenaires dans un co-investissement [l'usufruitier et le nu-propriétaire] devraient en retirer une rentabilité identique ou similaire ».

Pierre Carcelero prend ainsi l'exemple d'acquéreur de parts d'une SCI non assujettis à l'impôt sur les sociétés soumis à une fiscalité différente (IS pour l'un, part d'OPCI pour le deuxième et IR pour le dernier). « Le taux de rentabilité après impôt sera fondamentalement différent » et « alors même que la situation de ces trois investisseurs serait significativement différente, il ne viendrait pas à l'esprit de l'administration fiscale ou du juge de l'impôt de considérer qu'ils auraient dû retenir des prix d'acquisition différents ». Dès lors, Pierre Carcelero en conclut « que nous ne voyons pas le motif de droit consistant à considérer que la vérification de la normalité du prix payé par l'usufruitier pourrait reposer sur la cohérence des méthodes de valorisation entre les droits de l'usufruitier et ceux du nu-propriétaire ou sur le taux de rentabilité de leurs investissements respectifs. ».

La valorisation de l'usufruit doit, selon lui, « correspondre aux pratiques du secteur financier » (rejoignant ainsi Bernard Mailley) et « le reproche formulé à l'usufruitier d'avoir supporté un prix d'acquisition excessif à raison de ses droits sur le bien démembré et d'avoir à ce titre consenti un avantage anormal au nu-propriétaire ne devrait pas valablement pouvoir reposer directement sur la méthode de valorisation de la nue-propriété qui ne devrait à notre sens constituer tout au plus qu'un moyen de recoupement. »

L'exemple de coinvestisseur supportant une fiscalité différente au sein d'une même entreprise ne permet en réalité d'approcher le sujet que de manière éloignée. Le démembrement de propriété est certes un partage de la propriété comme pourrait l'être une association au sein d'une même entreprise, mais à la différence qu'il s'agit d'un partage dans le temps d'un même investissement, l'un succédant à l'autre.

Dans l'approche Mailley/Carcelero, on déconnecte la valeur de l'usufruit de la valeur de la nue-propriété et de la pleine propriété. En d'autres termes, on partage la propriété du bien de telle sorte que la somme des parties n'est plus égale au tout.

L'ingénierie financière étant pleine de ressources et d'imagination au même titre que l'ingénierie fiscale et patrimoniale, la vente d'usufruit comme un produit financier indépendant à des investisseurs est désormais proposée par des opérateurs et force est de reconnaître que dans cette situation, le prix de marché (la valeur de l'usufruit) est déterminé indépendamment de la valeur de la pleine propriété du bien. Ce qui est vendu, c'est un rendement annuel dont la valeur dépend, en l'espèce, exclusivement des conditions de marché (voir E.2.).

Cette approche est en opposition avec celle qui considère qu'usufruitier et nue-propriétaire sont liés et qu'il convient de considérer, comme l'indique Jean Aulagnier, que le démembrement n'est qu'un partage dans le temps des utilités du bien. « Pour l'économiste, démembrer la propriété consiste à partager c'est-à-dire à répartir entre plusieurs personnes les droits économiques attachés au bien possédé (répartir la jouissance attachée au bien). Il s'agit d'attribuer à un individu (l'usufruitier) les premiers revenus et un second individu (le nu-propriétaire) les revenus suivants restant à percevoir tant que le bien existe. Nous savons parfaitement que les juristes n'aiment pas en général qualifier le démembrement de propriété partagé. Ils n'aiment pas entendre dire que l'usufruit et la nue-propriété seraient des « morceaux » de la propriété. Et pourtant, tout nous semble conduire à cette analyse d'une propriété éclatée, partagée entre usufruitier et nu-propriétaire. L'usufruitier dispose immédiatement des premiers fruits le nu-propriétaire des fruits suivants. Ils se partagent les revenus, comme ils partageront d'ailleurs les autres attributs de la propriété.

C'est aujourd'hui la méthode communément reconnu par la jurisprudence (TA Toulouse, 5e ch ., 4 avr. 2023, n ° 2101921) qui considère que « Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode d'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire. »

Dans cette affaire, l'administration avait évalué l'usufruit temporaire en faisant la moyenne de quatre méthodes différentes : la méthode des DCF, la méthode dite « valorisation Aulagnier », la méthode par comparaison et l'application du barème fiscal. Le tribunal administratif a rapidement écarté les deux dernières et relevé des erreurs de calcul dans la deuxième pour ne retenir finalement que « la méthode de calcul retenue par le Conseil d'État, dans sa décision n° 412322, 412323 du 24 octobre 2018 et en retenant le taux de rendement locatif de 10,23 % ».

Cependant, et comme le souligne Mme Céline Guibé, rapporteur public (CE, 9e et 10e ch., 20 mai 2022, n° 449385, SC Ambroise D et M. et Mme D, concl. C. Guibé, note L. Benoudiz) : « il n'existe pas une seule et unique "bonne" méthode d'évaluation de l'usufruit des titres de sociétés non cotées. Nous l'avons dit, tout est affaire d'espèce ». Ainsi, la jurisprudence et la pratique reconnaissent d'autres méthodes mieux adaptées à des situations différentes de celle du démembrement d'un immeuble d'exploitation ou de parts de sociétés civiles détenant un tel immeuble entre associés liés.

Économiquement, il n'y a pas de différence de nature entre usufruit et nue-propriété [...] Le temps de jouissance du nu-propriétaire surviendra lorsque s'éteindra le temps de jouissance de l'usufruitier » (Jean Aulagnier, Droit & Patrimoine, sept. 2004, n° 129).

Retenir cette approche, c'est nécessairement s'assurer que ce partage est équitable et la seule équité envisageable est celle qui permet tant à l'investisseur en usufruit qu'en nue-propriété d'obtenir un taux de rendement interne de l'investissement identique, comme le soutient aujourd'hui le Conseil d'État et comme l'applique avec discernement la Cour d'appel de Nancy en considérant comme erronée une méthode ayant pour conséquence « que la somme de la valeur ainsi déterminée de l'usufruit et de la valeur vénale de la nue-propriété soit supérieure au prix d'acquisition de la pleine propriété ».

B. La valorisation de l'usufruit des parts d'une SCI : que doit-on actualiser ?

507

Ce principe fixé par le Conseil d'État reste-t-il pertinent (et surtout applicable) lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur de l'usufruit des parts d'une SCI ?

Avant de répondre à cette question, il semble nécessaire de revenir sur la méthode DCF qui est en pratique, tant pour les contribuables que pour l'administration et le juge de l'impôt la méthode privilégiée de valorisation, ce dont nous ne pouvons que nous féliciter.

1. Faut-il tenir compte de l'impôt (IR ou IS) ?

508

Comme son nom l'indique, la méthode des cash-flows actualisée consiste à actualiser des flux de trésorerie et uniquement des flux de trésorerie. Le calcul d'un résultat comptable et fiscal n'a d'autres intérêts dans cette méthode que de déterminer l'assiette fiscale sur laquelle sera calculé l'impôt qui fera l'objet d'un décaissement par le redevable. En effet, et comme semble le pratiquer désormais l'administration, il est indispensable de tenir compte de l'impôt qui fera l'objet d'un décaissement effectif par l'associé devant déclarer les revenus d'une société transparente. L'impôt à prendre en compte est évidemment celui qui sera supporté par le titulaire des droits, l'acquéreur de l'usufruit, mais aussi par le nu-propriétaire à l'issue du démembrement : la question en effet est bien de déterminer le flux de revenu net d'impôt qui fera l'objet de l'actualisation nécessaire à la détermination de la valeur de l'usufruit. On actualise tous les flux, mais uniquement les flux de trésorerie dans la méthode DCF.

La prise en compte de l'impôt sur le revenu, on l'a dit (voir § 501 (20190730150406293.html#501)) se trouve être contraire à l'approche retenue par Jean Aulagnier et Pierre Fernoux.

Pour eux, la fiscalité de l'usufruitier n'a pas à être prise en compte pour déterminer la valeur vénale de l'usufruit, notamment aux motifs, d'une part, que la situation fiscale de l'usufruitier est susceptible de variations et, d'autre part, que la pleine propriété comprenant le droit d'usufruit, le prix de cette pleine propriété n'est jamais fonction de la situation personnelle de l'acquéreur. Enfin tenir compte de cette situation fiscale entraînerait obligatoirement une réduction de la valeur de l'usufruit et corrélativement une augmentation de la valeur de la nue-propriété, ce qui reviendrait à transférer la charge fiscale du premier sur le second (J. Aulagnier précité, p. 21 ; sur la comparaison des deux méthodes, M. Iwanesko et F. Rodriguez, « Le notaire, l'évaluation des droits de propriété démembrés et l'article 751 du CGI », JCP N 1994, n° 26, prat. 3039). La « méthode Aulagnier » précise toutefois que la taxe foncière doit être prise en compte car il s'agit d'une charge réelle.

En synthèse, deux approches contraires sont donc envisageables : celle prônée par Bernard Mailley, considérant que la valeur d'un usufruit doit tenir compte de critères subjectifs pour l'usufruitier tel que le rendement réel et l'impôt supporté, ce qui implique que l'équation U + NP = PP n'est pas indépassable, et celle de Jean Aulagnier qui considère qu'usufruit et nue-propriété doivent être évalués uniquement au regard du taux de rendement du bien, indépendamment de toute fiscalité supportée par l'acquéreur.

Pierre Fernoux abonde sans réserve en ce sens (P. Fernoux, « Revisitons le passé à l'aune du but principalement fiscal », RDF 30 mai 2019, n° 22) :

« En vérité, l'évaluation économique du droit démembré se présente sous deux aspects complémentaires l'un de l'autre. Un bien ou un droit n'a qu'une seule valeur, et celle-ci est objective. Elle repose sur l'actualisation du flux de revenus futurs, selon la bonne vieille méthode toujours chère au doyen Aulagnier. Elle n'est ni plus ni moins qu'une évaluation par le rendement, méthode classique déjà applicable en matière d'évaluation de la pleine propriété d'un bien immeuble. Cette valeur objective doit cependant s'accommoder d'une valeur subjective, celle calculée par l'acquéreur désireux de mesurer l'intérêt qu'il aurait à réaliser cet investissement. Et logiquement, pour les besoins de l'actualisation du flux de revenus, il prend alors en compte le rendement remontant de la SCI, mais net de l'impôt dû à raison de celui-ci. Maintenant, faut-il attribuer à l'usufruit la valeur objective ou la valeur subjective de ce droit pour déterminer la base d'imposition à soumettre à l'article 13, 5 du CGI ? ».

509

En vérité, il semble parfaitement possible de réconcilier ces deux approches et de faire se rejoindre valeur subjective et valeur objective car il faut reconnaître que nous ne partageons pas l'idée qu'il puisse exister deux valeurs différentes…

Comme l'a rappelé le Conseil d'État le 24 octobre 2018, « l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date ou l'acquisition est intervenue ». Ainsi, on ne recherche pas une valeur qui serait « vrai » ou « juste » dans l'absolu mais le prix qu'un acheteur serait prêt à payer pour acquérir un bien et qu'un vendeur serait prêt à accepter pour vendre ce bien. Et sous ce prisme, force est de reconnaître qu'aucun acheteur ne procéderait à une acquisition d'un usufruit, c'est-à-dire d'une suite de flux ou d'une utilité limitée dans le temps, sans valeur terminale, et dont le rendement net après impôt serait négatif ! La prise en compte de l'impôt est donc indispensable et est un critère déterminant dans l'évaluation économique de la valeur d'un usufruit.

Faut-il pour autant abandonner l'équilibre cher au doyen Aulagnier qui veut que U + NP = PP et retenir la proposition de Bernard Mailley ? sûrement pas ! Car pour résoudre ce dilemme, il convient simplement d'appliquer la formule que le Conseil d'État nous a donné le 24 octobre 2018 : *« Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode d'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne (TRI) de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire. ».*

Ainsi, il suffit de procéder à un (très) léger ajustement de la méthode Aulagnier qui préconise de retenir le taux de rendement net de charges usufructuaires vers le taux de rendement interne de l'investissement, c'est-à-dire le taux de rendement net de charges usufructuaires intégrant l'impôt. Car, en effet, si l'usufruitier est soumis à une fiscalité sur ses revenus, nul ne doute que le nu-propriétaire redevenu plein propriétaire à l'extinction de l'usufruit supportera également un impôt sur le revenu !

L'administration retient également cette approche en calculant un impôt « théorique » sur les revenus des sociétés civiles immobilières dans son guide d'évaluation (https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/guides_notices/guide_eval_entreprises.pdf) (https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/guides_notices/guide_eval_entreprises.pdf)) : précisant, page 103, que « pour les SCI non soumises à l'IS, la déduction d'un impôt fictif permet de prendre en compte l'inégalité des situations ». La jurisprudence abonde également en ce sens (TA Toulouse, 5e ch., 4 avr. 2023, n° 2101921) en relevant que « le taux de rendement interne de l'investissement se calcule après impôt ».

Retenir un impôt, réel ou théorique, dans l'évaluation d'un usufruit n'interdit pas de retenir une méthode « homogène » dans l'évaluation respective de l'usufruit et de la nue-propriété ; il suffit que le taux d'actualisation soit identique, c'est-à-dire qu'il convient de choisir le taux de rendement interne (TRI) de l'investissement après impôt pour actualiser les flux.

Reprenons l'exemple soumis à l'appréciation du Conseil d'État d'un immeuble d'une valeur en pleine propriété de 730 000 € présentant un rendement locatif de 5,26 %. Quelle serait la valeur de l'usufruit sur 22 ans et de la pleine propriété, calcul nécessaire pour s'assurer que l'actualisation à l'infini permet bien d'obtenir un rendement identique pour l'usufruitier et le nu-propriétaire, selon qu'on tienne compte ou non de l'impôt ? Le tableau ci-dessous synthétise ces différentes valeurs selon les hypothèses :

Éléments	**Sans indexation**	**Avec indexation 3 % / an**
Durée du démembrement	22 ans	22 ans
Rendement locatif brut	38 398	38 398 + 3% par an
Taux d'actualisation	5,26 %	8,26 %
Valeur d'un usufruit de 22 ans	493 665	485 969
Rendement locatif après impôt (30 %)	26 879	26 879 + 3% par an
Taux d'actualisation (5,26 % - 30 % d'impôt)	3,68 %	6,68 %
Valeur d'un usufruit de 22 ans	400 505	392 917

Dans ces hypothèses, l'actualisation à l'infini du revenu au taux indiqué donne bien une valeur de la pleine propriété de 730 000 €. Comme on peut le constater, avec ou sans indexation du revenu, la valeur de l'usufruit sur 22 ans varie peu dès lors que le taux d'actualisation tient compte de l'effet de l'indexation du loyer, que le calcul soit réalisé avant ou après impôt.

L'effet de l'impôt est cependant sensible puisque la valeur de l'usufruit est réduite d'environ 20 %. Pour autant, il y a bien un équilibre entre l'usufruitier et le nu-propriétaire dans le partage de la valeur de la pleine-propriété, chacun ayant le même taux interne de rentabilité de leur investissement (26 879 € / 3,68% = 730 000 €) !

Cependant, et sans surprise, le revenu réel perçu par l'usufruitier étant plus faible durant la phase de détention et le taux d'actualisation étant également plus faible (ce qui a pour effet de moins dévaloriser les flux les plus lointains qui reviendront au nu-propriétaire), il s'opère un basculement de la valeur de l'usufruit vers le nu-propriétaire… mais cela correspond à la réalité de l'investissement !

L'usufruitier disposera effectivement d'un revenu réduit compte tenu de l'impôt tandis que le nu-propriétaire, en retenant un taux de rendement réel de son investissement intégrant l'impôt qu'il aura en tout état de cause à sa charge apprécie mieux la véritable rentabilité de son investissement.

Au demeurant, aucun investisseur avisé ne fait raisonnablement abstraction de l'impôt… Ainsi d'un investissement en SCPI dont les rendements actuels tournent avant impôt entre 4 % et 4,5 %, montant largement supérieur à ce que procure un placement financier actuel sans pour autant rencontrer un engouement des investisseurs… Après impôts sur le revenu, prélèvements sociaux et IFI, le rendement net devient comparable voire inférieur à celui disponible sur le marché et c'est bien ce rendement net d'impôt qu'un investisseur examine !

Il est donc possible d'appliquer la « méthode Aulagnier », de respecter l'équilibre U + NP = PP, de respecter les principes fixés par le Conseil d'État tout en intégrant, parce que c'est une charge effectivement supportée et prise en compte par l'investisseur, l'impôt sur le revenu acquitté tant par l'usufruitier que par le nu-propriétaire sur le revenu perçu durant toute la vie du bien.

On a ainsi réconcilié valeur subjective et valeur objective, cette dernière n'étant en réalité qu'une valeur « théorique », une valeur incomplète puisqu'elle omet la charge fiscale supportée par les différents bénéficiaires des revenus, une valeur « abstraite » qui ne permet dans aucune hypothèse d'obtenir *« un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande ».*

2. Faut-il tenir compte des remboursements d'emprunts de la SCI ?

510

Dans la méthode DCF, on actualise tous les flux et uniquement les flux de trésorerie.

Pour autant, cette méthode n'a pas été appliquée par la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1re ch., 15 février 2018, n° 16NT01325 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=16&numero=01325&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610051.xml&date=02-15), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel : RJF 6/202018, 582) (voir annexe A7), en contradiction avec les conclusions éclairantes et parfaitement construites du rapporteur public, Thurian Jouno (Th. Jouno, Acquisition de l'usufruit de droits sociaux à prix minoré : valeur à inscrire au bilan, concl. ss CAA Nantes, 1re ch., 15 février 2018, n° 16NT01325 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=16&numero=01325&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610051.xml&date=02-15), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel : RJF 6/202018, C 582.).

Le contribuable avait procédé à la cession de l'usufruit temporaire des titres de la SCI LBA le 29 décembre 2009 au prix de 460 €, soit 46 % de la valeur de la pleine propriété des titres de la SCI au capital de 1 000 € constitué le 6 octobre 2009. L'administration a considéré que la valeur de l'usufruit temporaire devait être déterminée par l'actualisation du revenu foncier, après prise en compte d'un impôt sur les sociétés au taux de 33,33 %, soit un montant de 632 993 €.

Les éléments factuels repris par la cour manquent de précisions, mais on peut suivre néanmoins la méthode appliquée par l'administration. La cour nous indique que le montant du loyer annuel est de 187 116 € hors taxes, mais qu'après déduction « des charges telles que les intérêts d'emprunt, les honoraires d'expertise comptable, les frais d'assurance liés à l'emprunt, la taxe foncière », le revenu net s'établit à 76 190 € avant impôt. Compte tenu des montants indiqués (110 916 € de charges annuelles), il semble assez évident que les charges intègrent également l'amortissement comptable du bien, sauf à imaginer que les honoraires de l'expert-comptable représentent plusieurs dizaines de milliers d'euros (ce qui, d'expérience, est assez peu fréquent).

Le taux d'actualisation retenu par la cour est celui proposé par l'administration, soit 5 % tandis que le contribuable proposait de retenir le taux de 9,45 % correspondant au taux de rendement de l'immeuble.

On peut s'assurer que l'actualisation d'un revenu de 50 796 € (correspondant à un revenu de 76 190 € duquel est déduit un impôt de 33,33 %) permet effectivement d'aboutir à une valorisation de l'usufruit au taux de 5 % sur une durée de 20 ans, durée du démembrement, de 632 993 €.

Ce « revenu » de 50 796 € est un résultat comptable net d'impôt comme le relève, sans être contredit par l'administration, le contribuable qui estime que « pour déterminer les revenus, il faut prendre en compte l'investissement, l'endettement et l'amortissement du bien [ce dernier terme semble en l'occurrence inadéquat puisque l'amortissement du bien n'est pas un flux de trésorerie] ce qui a pour conséquence qu'elle ne pourra appréhender aucun flux de trésorerie au titre de son usufruit tant que la SCI LBA n'aura pas remboursé son emprunt ».

Pour autant, cet argument n'est pas retenu par la cour qui considère « que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le revenu futur attendu devait être apprécié au regard d'un résultat comptable distribuable et d'une situation de trésorerie disponible ».

Avant d'examiner en droit cet argument, relevons que cette décision est entachée d'une erreur de raisonnement manifeste puisqu'elle applique une méthode consistant à actualiser des flux de trésorerie sur des résultats comptables. Pour le rapporteur public, « l'administration a erré dans son application de la méthode DCF ». Ainsi, la critique faite à l'administration « de n'avoir pas tenu compte des remboursements du capital emprunté [...], exacte au plan des faits, est fondée. » En toute logique Thurian Jouno considère qu'en « recourant, pour évaluer l'usufruit des droits sociaux détenus par les requérantes, à la seule méthode DCF tout en l'appliquant de manière viciée, l'administration ne démontre pas que cet usufruit était sous-évalué ». Ainsi, la méthode est intrinsèquement viciée lorsqu'on actualise non pas des flux de trésorerie, mais des résultats comptables.

Pour la cour, la prise en compte « d'un résultat comptable distribuable et d'une situation de trésorerie disponible » pour « déterminer une valeur de rendement » ne serait « applicable qu'aux seules sociétés de capitaux rémunérant leurs actionnaires ou porteurs de parts par des distributions [...] ».

Il y a là aussi, manifestement, une erreur entachant irrémédiablement cette décision car on peine à comprendre la distinction qu'il y aurait en droit entre les dividendes, les fruits, versés par une société civile de ceux versés par une société de capitaux. En outre, la Cour de cassation (cass. com. 10 février 2009, n° 07-21806 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=07-21806&sp=/juri/cass/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/20/25/69/JURITEXT000020256925.xml&date=2009-02-10), FSPB, DGFIP c/ M. Cadiou : JurisData n° 2009-046999 ; Dr. fisc. 2009, n° 12, comm. 252, note R. Gentilhomme ; JCP E 2009, comm. 1287, note H. Hovasse ; Dr. sociétés 2009, comm. 71, note R. Mortier ; RJF 5/2009, n° 514) (voir annexe A5) rappelle que « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature de fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par l'assemblée générale, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé ». Est-il utile de préciser qu'en l'occurrence cette décision concernait une société civile ?

On peut cependant essayer de comprendre le raisonnement qui a conduit l'administration et la cour à actualiser, pour déterminer la valeur de l'usufruit des parts de la SCI, un résultat comptable et non les flux de trésorerie. Comme le relève en effet Thurian Jouno dans ses conclusions, « dans le cas où l'usufruitier de parts sociales est à même de déterminer la politique de distribution, il est raisonnable de lui prêter une volonté de maximisation de ses gains. Volonté qui implique, dans une société de personnes, une absence complète de mise en réserve, lorsque les statuts ne contraignent pas les associés à y procéder (« réserves statutaires ») ». On ne peut que partager cette approche.

Le droit de vote concernant l'affectation des bénéfices est réservé à l'usufruitier (c. civ. art. 1844 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1844&idspad=LEGIARTI000038799283)). Dès lors, pour quelles raisons l'usufruitier renoncerait-il à affecter en dividendes l'intégralité du bénéfice distribuable ? Ainsi, c'est en réalité l'existence de ce droit qu'a actualisé l'administration suivie par la cour et non le flux de trésorerie, comme elle aurait dû le faire.

La difficulté est en pratique facile à résoudre lorsque le bénéfice distribuable est statutairement limité. En effet, si les statuts limitent le montant du bénéfice distribuable au montant de la trésorerie disponible à la clôture, alors dans ce cas, l'usufruitier ne dispose pas d'autres alternatives que d'affecter en réserve la différence entre le résultat comptable et la trésorerie disponible. Cette solution non seulement ne souffre aucune critique en droit mais correspond également au calcul économique de la valeur de l'usufruit lorsque la méthode DCF est appliquée. Il y a, en effet, parfaite cohérence entre l'estimation de la valeur de l'usufruit et les droits de l'usufruitier. Dans cette situation, le juriste et le financier ont travaillé main dans la main, le second actualisant les flux de trésorerie disponible selon les droits accordés par le premier (voir § 542 (20190730150406293.html#542)).

Cependant, les statuts de la SCI LBA, au cas d'espèce, ne prévoyaient pas une telle limitation du bénéfice distribuable. Dès lors, pour quelles raisons l'usufruitier n'aurait-il pas affecté en dividendes l'intégralité du résultat comptable, puis inscrit celui-ci en compte courant d'associé faute de pouvoir effectivement l'appréhender pour enfin le percevoir lorsqu'il en aurait eu la possibilité ? C'est en effet le chemin qu'aurait dû emprunter l'administration (et non actualiser des résultats comptables) : déterminer la quote-part de résultat distribuable, mais non appréhendable venant s'inscrire en compte courant puis, à l'issue du remboursement de l'emprunt, actualiser au fur et à mesure de la perception des loyers, les remboursements de compte courant possible, y compris bien évidemment au-delà de la période de démembrement, jusqu'à complet apurement de celui-ci. L'application de la méthode DCF conduit en effet à **rechercher uniquement les flux de trésorerie disponible**, que ceux-ci proviennent d'une distribution de dividendes ou d'un apport ou d'un remboursement de compte courant **en les rattachant à la période où ils sont appréhendables**, exercice indispensable compte tenu de l'effet de l'actualisation.

Sur la base des informations données par la cour, il est possible d'estimer l'impact d'une telle opération pour la SARL Luccotel et la SCI LBA.

Si la SARL Luccotel avait chaque année affecté son droit au dividende en compte-courant, elle aurait disposé au terme des 20 ans (durée de l'emprunt) d'un compte courant de 1 000 000 € (20 x 50 000 € de résultat comptable non appréhendé faute de trésorerie pour le faire). Elle aurait ensuite pu prélever ce compte courant à raison de 100 000 € par an, montant du cash-flow généré par la SCI annuellement. La valeur de son usufruit, compte tenu de l'absence de perception du moindre flux durant les 20 premières années en raison de l'emprunt remboursé, doit donc tenir compte de la somme actualisé, de l'année 21 à l'année 30, d'un flux de 100 000 € au taux d'actualisation retenu.

Cette méthode a été baptisée par l'administration et par la cour d'ap-pel de Nantes (CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19NT03876 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=19&numero=03876&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/42/59/05/CETATEXT000042590564.xml&dat 11-30), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel, concl. L. Chollet, note L. Benoudiz : JurisData n° 2020-021544), la méthode dite « Benoudiz ».

Suivant les conclusions du rapporteur public Laure Chollet reprenant elle-même la position d'Émilie Bokdam-Tognetti, la cour d'appel de Nantes écarte cette méthode au motif « qu'elle peut entraîner, d'une part, un décalage d'ampleur entre la trésorerie et le bénéfice comptable dans le temps et, d'autre part, un report du versement du solde des distributions en fonction de la trésorerie à une date indéterminée. Compte tenu de ces incertitudes au-delà de l'expiration de la durée de l'usufruit, cette autre méthode utilisée par l'administration doit être écartée ».

La cour, suivant les conclusions des rapporteurs publics privilégie « la simplicité » en retenant la méthode « DCF classique » « plus praticable et, par suite, préférable ».

Si certains auteurs (V. Streiff, Nouvelles précisions sur la méthode d'évaluation de l'usufruit à durée fixe de parts sociales : Solution Notaire Hebdo, 18 févr. 2021, n° 6, inf. 13) approuvent cette approche compte tenu de l'incertitude d'appréhender un flux « dont on ne sait, eu égard aux multiples aléas qui peuvent affecter la vie de la SCI, quand il apparaîtra, ni même s'il apparaîtra un jour », d'autres (M. Leroy, Évaluation de l'usufruit temporaire des parts et dividendes distribués après reconstitution de la trésorerie : RFP 2021, n° 1, prat. 1) y voient « un risque considérable ».

Quand bien même cette méthode porterait le patronyme d'un des auteurs de cet ouvrage, on se range sans états d'âme à l'avis des rapporteurs publics, de la cour et de Vivien Streiff même si Émilie Bokdam-Tognetti estime que cette méthode est « la plus sophistiquée et sans doute la plus intellectuellement séduisante » et malgré le fait qu'y renoncer « conduit à omettre une partie de l'avantage économique potentiel lié à l'usufruit ».

Pour Michel Leroy, « la société IS peut donc acquérir un usufruit pour une valeur pratiquement nulle, tout en espérant à terme des revenus, acquis, en quelque sorte, gratuitement. [...] l'administration fiscale pourrait y voir un abus destiné à contourner les dispositions de l'article 13, 5 du CGI. Il y a, en effet, application de l'article 238 bis K du CGI contraire aux objectifs poursuivis pas les auteurs du texte lorsque la société pendant le temps de l'usufruit n'est pas susceptible de dégager un résultat taxable, en raison du montage opéré ».

Cette argumentation ne convainc pas. En effet, les flux éventuellement appréhendés à l'issue de la période de démembrement et placé en compte courant par l'usufruitier correspondent à la différence entre le résultat comptable (et donc imposé et taxé entre les mains de l'usufruitier) et la trésorerie disponible : on ne peut considérer qu'ils ont été acquis « gratuitement » puisqu'ils ont subi l'imposition. De la même manière, l'éventuelle faiblesse de la valeur de l'usufruit temporaire, faute de flux, n'a pas de liens avec une éventuelle absence de « résultat taxable » : il y a bien au contraire un résultat taxable mais non distribuable. En outre, et comme cela a été rappelé précédemment, il ne peut y avoir d'abus de droit du seul fait d'une sous-valorisation éventuelle de l'usufruit dès lors que les avantages politiques sont réels et que la cession entraîne des effets économiques réels.

Enfin, ce n'est pas parce que la valeur de l'usufruit est faible, indépendamment de l'appréhension ou non du potentiel compte-courant, qu'il a là un montage fragile au regard de l'abus de droit.

On sait, avant même que l'article L. 64 A du LPF n'existe, qu'il ne fallait pas que l'avantage économique ne soit jugé « négligeable », « minime » ou « sans commune mesure avec l'avantage fiscal tiré de ces opérations » à la suite de la décision Garnier Choiseul Holding (CE, 9e et 10e ss-sect., 17 juill. 2013, n° 356523, min. c/ SAS Garnier Choiseul Holding, n° 352989, min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding et n° 360706, min. c/ SARL Garnier Choiseul Hol-ding : Dr. fisc. 2013, n° 41, comm. 477, concl. F. Aladjidi, note F. Deboissy et G. Wicker ; Dr. sociétés 2013, comm. 194, J.-L. Pierre ; RJF 11/2013, n° 1064, chron. E. Bokdam-Tognetti, p. 883. - V. M. Cozian, F. Deboissy et M. Chadefaux, Précis de fiscalité des entreprises : LexisNexis, 2020-2021, 44e éd., spéc. n° 1180). Mais dans cette affaire, aucun autre avantage qu'économique ne pouvait être invoqué par le contribuable, s'agissant du rachat d'une société sans activité au sein de laquelle le coquillard appréhendait l'intégralité de la trésorerie disponible dans la société pour finir par la faire disparaître. Dans cette situation, le seul et unique intérêt autre que fiscal ne pouvait être que l'avantage économique retiré de cette acquisition consistant en une différence entre la valeur d'acquisition et la trésorerie disponible.

Dans la stratégie de cession d'usufruit temporaire, on cherche surtout à transférer au preneur des locaux détenus par la SCI une occupation sécurisée, pour un coût contrôlé, avec des pouvoirs d'administration et de gestion du bien, pour une durée limitée afin de ne pas impacter le patrimoine de la société d'exploitation de manière permanente comme l'entraînerait la détention de la pleine propriété du bien, alourdissant la valeur patrimoniale de la société, complexifiant sa cession ou l'entrée dans le capital de futurs associés.

L'existence d'un avantage économique faible du fait d'une acquisition pour une valeur modeste de l'usufruit temporaire déterminée par une actualisation des flux sur la durée du démembrement permet essentiellement de démontrer l'absence d'acte anormal de gestion : l'opération n'est pas réalisée au détriment de la société mais bien à son avantage, même s'il est faible dès lors qu'il vient s'additionner à l'ensemble des autres motivations.

Au demeurant, cette interrogation sur la prise en compte de l'éventuel compte courant à l'issue du démembrement n'existe que si les droits de l'usufruitier n'ont pas été limités au montant de la trésorerie disponible. Vivien Streiff abonde en ce sens : « on ne saurait trop conseiller au praticien d'adapter les statuts pour interdire toute distribution au-delà de la trésorerie disponible ».

Le Conseil d'État (CE 9e et 10e ch., 30 sept. 2019, n° 419855, Sté Hôtel-Restaurant Luccotel : JurisData n° 2019-016700 ; Dr. fisc. 2019, n° 48, comm. 465, concl. É. Bokdam-Tognetti, note P. Fernoux ; Dr. fisc. 2019, n° 42, act. 443, M. Buchet) confirme qu'une telle disposition est envisageable en précisant que « le montant des distributions prévisionnelles [...] peut être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunts ou des éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société ».

Pour Émilie Bokdam-Tognetti, « il convient de tenir compte d'éventuelles stipulations limitatives dans les statuts et des besoins d'autofinancement de la société » et qu'une distribution ne peut s'envisager que s'il n'existe pas de « stipulations statutaires prohibant une telle affectation ».

Dans un article publié sur son site (http://vhavocats.fr/dossiers-Valorisation-de-l%E2%80%99usufruit-de-parts-de-SCI,-les-probl (http://vhavocats.fr/dossiers-Valorisation-de-l%E2%80%99usufruit-de-parts-de-SCI,-les-probl) %C3%A9matiques-en-suspens.-Ref-109.html) complétant une interview accordée à l'Agefi Actifs (V. Halbout, Affaire Luccotel : une délicate évaluation : Agefi Actifs, 8 au 21 janv. 2021, p. 25), Vincent Halbout considère « qu'une telle stipulation ne serait, à notre avis, pas neutre fiscalement pour le redevable de l'impôt correspondant à la partie du dividende non distribué. [...] L'usufruitier sera effectivement imposable à l'IS sur la partie du résultat correspondant à la trésorerie disponible, l'autre partie du résultat comptable sera imposable au nom du nu-propriétaire, dès lors qu'elle n'aura pas été imposée au nom de l'usufruitier. Ainsi, le nu-propriétaire sera taxé au titre des revenus fonciers sur une partie du résultat de la SCI [...] »

On peine à voir sur quelle base l'administration pourrait envisager de taxer le nu-propriétaire... D'une part, l'intégralité du résultat comptable imposable de la SCI est taxée entre les mains de l'usufruitier : aucune quote-part de résultat « n'aura pas été imposée au nom de l'usufruitier ». En outre, l'article 238 bis K du CGI est explicite : « Lorsque des droits dans une société [transparente] sont inscrits à l'actif d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés [...], la part de bénéfice correspondant à ces droits est déterminée selon les règles applicables au bénéfice réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits ».

Enfin, Vincent Halbout s'inquiète que l'administration puisse voir « dans la renonciation de l'usufruitier à voter un dividende correspondant au résultat comptable [...] une libéralité en faveur du nu-propriétaire ».

Une telle affirmation méconnaît la décision de la Cour de cassation (cass. com., 18 déc. 2012, n° 11-27.745 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=11-27745&sp=/juri/cass/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/26/81/54/JURITEXT000026815425.xml&date=0002-11-30) : JurisData n° 2012-029941 ; Bull. civ., IV, n° 230 ; Dr. sociétés 2013, comm. 44, H. Hovasse ; JCP E 2013, 1066 ; JCP N 2013, act. 159 ; JCP N 2013, 1010, J.-P. Garçon ; JCP G 2014, 183, F. Deboissy et G. Wicker) qui rappelle que « les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant la constatation de l'existence de sommes distribuables par l'organe social compétent ». En outre, on ne peut donner ce qui ne nous appartient pas. En l'occurrence, la

société cessionnaire a acquis un usufruit déterminé sur la base des flux de trésorerie disponible pendant la période de démembrement. Elle avait connaissance, lors de cette acquisition, des limitations statutaires portant sur l'affectation du résultat expressément limitée à la trésorerie disponible. Elle n'a donc acquis et valorisé que les droits auxquels elle pouvait espérer prétendre : le montant de la trésorerie disponible durant la période de démembrement. Comment pourrait-elle renoncer à un droit qu'elle savait ne pas détenir et qu'elle n'a pas non plus valorisé dans cette opération ?

Ainsi, la cour administrative d'appel de Nantes, en suivant les conclusions du rapporteur public, apporte sécurité et visibilité sur la méthode consistant à actualiser les flux de trésorerie attendus sur la période de démembrement aux contribuables qui n'auraient pas eu la bonne idée de limiter les distributions dans les statuts de la SCI à la seule trésorerie disponible à la clôture des comptes.

C. Quel taux retenir pour actualiser les flux permettant de valoriser l'usufruit de parts de SCI ?

511

Le Conseil d'État fixe comme principe que le taux d'actualisation doit être le Taux de Rentabilité Interne (le TRI) de l'investissement, seule méthode permettant de garantir que la valeur actualisée de l'usufruit additionné à celle de la nue-propriété est égale à la valeur de la pleine propriété.

Afin d'exposer le plus clairement possible la situation, il ne semble pas inutile de rappeler ce qu'est un TRI. Le TRI est le Taux de Rentabilité Interne, exprimée annuellement, d'un projet. En mathématique financière, on dit également qu'il s'agit du taux d'actualisation qui annule la Valeur Actuelle Nette (la VAN) d'une série de flux financier.

Prenons l'hypothèse d'un investissement présentant les flux suivant :

Année	0	1	2	3	4
Flux	– 100	30	40	40	40

Il s'agit d'un projet qui consiste à investir 100 afin de récupérer pendant quatre ans un flux positif de 30 la première année puis de 40 les trois années suivantes.

Le TRI de cet investissement est le taux (TRI) tel que :

$$\sum_{1}^{4} \frac{\text{Flux } n}{(1 + \text{TRI})^n} - 100 = 0$$

(20190730150406293_1.jpg)

En d'autres termes, on cherche le taux tel que l'actualisation des flux 1 à 4 permette d'obtenir une VAN égale au montant de l'investissement de départ, soit 100 dans cet exemple.

En l'occurrence, le TRI de cet investissement est de 17,6 %. Cela signifie que si on actualise au taux de 17,6 % les flux des années 1 à 4, nous obtiendrons une VAN de + 100, montant de l'investissement de départ.

TRI et VAN sont donc inextricablement liés : le TRI dépend du montant de l'investissement de départ. Ce qui implique qu'il est indispensable, pour déterminer un TRI, de connaître la valeur actuelle nette de départ, autrement dit la valeur de la pleine propriété des parts de la SCI.

512

Une telle méthode est-elle applicable s'agissant d'une SCI détenant un actif immobilier financé par emprunt ?

Pour répondre à cette question, nous devons poser en préalable comme hypothèse que la valeur de la pleine propriété de la SCI (c'est-à-dire, en fait, la VAN) est égale au montant des apports réalisés par ses associés, hypothèse en réalité communément admise lorsque la SCI vient d'être constituée, que celle-ci n'a perçu encore aucun revenu ni remboursé aucune échéance d'emprunt. Affirmer ainsi qu'une SCI au capital de 1 000 € détenant un actif de 1 000 000 € financé par un emprunt de 999 000 € vaut 1 000 € ne semble pas une hypothèse trop difficile à concevoir.

Or, dans la méthode des DCF, seuls doivent être pris en compte les flux de trésorerie. Cela implique qu'il convient de calculer le taux interne de rentabilité (TRI) de l'investissement en tenant compte non seulement des apports en capital mais également des apports en compte-courant (les investissements de départ qui vont former la VAN). Pour l'investisseur, un apport en trésorerie placé en compte courant ou en capital est équivalent ; il pourra cependant escompter récupérer ultérieurement son compte courant de manière plus simple qu'en procédant à une réduction de capital, raison pour laquelle est souvent privilégié l'apport en compte-courant plutôt qu'un apport en capital. C'est en tenant compte de l'ensemble de ces flux incluant la VAN qu'il est alors possible de déterminer un TRI.

513

Reprenons l'exemple de Luccotel et intégrons comme hypothèse que les associés de LBA ont financé par un apport en compte courant complémentaire à l'apport en capital de 1 000 € le montant des frais d'acquisition estimé à 10 % du prix de la construction, soit 200 000 €. Pour déterminer le TRI de leur investissement, il convient de déterminer les flux prévisionnels à l'infini, soit sur les cent prochaines années compte tenu d'une VAN de 201 000 €.

Au cours des vingt premières années, et comme on l'a vu, le revenu est nul. Au cours des treize années suivantes, le revenu passe à 125 000 € (plus de charges de remboursement, plus de charges financières mais un peu plus d'impôt compte tenu de l'absence de charges financières déductibles). À partir de la 34e année, le revenu passe à 107 000 €. En effet, la déduction relative à l'amortissement sur 33 ans du bien est terminée et l'impôt augmente. Le TRI d'un tel investissement (– 201 000 €, 0 € pendant 20 ans, + 125 000 € pendant 13 ans et + 107 000 € pendant 67 ans) est de 10,10 %. Dis autrement, il faut actualiser ces flux sur les 100 prochaines années au taux de 10,10 % pour obtenir une VAN de 200 000 €, montant de l'investissement de départ.

Si on indexe ces revenus sur une base annuelle de 2 % l'an, le TRI passe à 14,7 %. Ces taux peuvent sembler élevés mais n'oublions pas que le bien génère un rendement de 9,45 %. Si l'on simule la même opération, mais avec un rendement locatif de 5 %, le TRI de l'investissement passe à 3,12 % sans inflation du loyer et à 5,8 % avec 2 % d'inflation du loyer.

Jusqu'à ce stade, rien ne semble indiquer qu'une telle méthode ne puisse être pratiquée. Mais qu'en serait-il si les associés de la SCI LBA avaient réussi à faire financer l'intégralité de l'opération par emprunt, sans aucun autre apport que les 1 000 € de capital ? Dans cette hypothèse, inévitablement, le TRI de l'investisseur explose ! Sans inflation du loyer, le TRI de l'opération est de 14,1 % et passe à 32 % avec 2 % d'inflation du loyer et 47 % avec 3 %. En effet, n'oublions pas qu'on recherche le taux TRI tel que la VAN, la valeur de la pleine propriété soit égale à 1 000 €. Relevons également qu'en conséquence de cette méthode, la valeur de l'usufruit temporaire des parts de la SCI est une valeur qui, en tout état de cause, ne saurait dépasser la valeur de la pleine propriété de la SCI, soit 1 000 €, montant de la VAN de l'investissement.

Pour autant, est-il raisonnable d'exiger que l'acquisition de l'usufruit temporaire des parts de la SCI par la société d'exploitation soit réalisée sur la base du taux de rendement interne de l'investissement par les associés de la SCI qui peut, comme on vient de le voir dans l'hypothèse d'un financement externe intégral, être extraordinairement plus élevé voir anormalement élevé ? La société d'exploitation ne doit-elle réaliser l'acquisition de l'usufruit temporaire des parts de la SCI, qui lui confère des droits et des pouvoirs essentiels, qu'à la condition d'obtenir un rendement interne identique à celui des associés initiaux de la SCI, à 14 %, 32 % ou 47 % par an pour reprendre ces derniers exemples ?

L'hypothèse d'un TRI excessivement élevé n'a rien d'extraordinaire et se trouve même être assez courante tant l'effet de levier de la dette est puissant. « L'endettement procure un effet démultiplicateur pour les actionnaires lié au fait qu'ils n'apportent qu'une partie des sommes sur lesquelles porte un investissement. Cet effet est d'autant plus important que le taux d'intérêt auquel est souscrit l'emprunt est faible et que la rentabilité économique de l'investissement est importante » (www.lafinancepourtous.com/decryptages/entreprise/gestion-et-comptabilite/effet-de-levier.).

514

Prenons l'hypothèse d'une entreprise acquise par un fonds d'investissement sur une valorisation de sept fois l'Ebitda ou de dix fois ses cash-flows. Son Ebitda est de 100, soit une valorisation de 700, tandis que son cash-flow après impôts est de 70. L'acquisition est financée par emprunt à hauteur de 450 sur sept ans au taux de 1,5 % par an, le fond n'investissant en capital que 250. À l'issue des sept ans, l'entreprise est revendue sur la base du même multiple : dix fois ses cash-flows. On suppose que le revenu progresse uniquement de 0,5 % par an. Quel est le TRI de l'investissement ?

En l'absence d'endettement, il est de 0,5 %, taux de croissance du revenu. Du fait de l'effet de levier de la dette, il atteint 15 %, objectif habituel de TRI d'un fond.

Année	0	1	2	3	4	5	6	7	VT
Flux	70	71	71	71	72	72	72	72	725
Emprunt	– 68	– 68	– 68	– 68	– 68	– 68	– 68	– 68	– 68
Flux net	– 250	+ 2	+ 3	+ 3	+ 3	+ 4	+ 4	+ 4	– 725

L'effet de levier de la dette est la technique qui rend possible d'obtenir un TRI de 15 % en investissant dans une entreprise acquise 700 et revendue sept ans plus tard 725 avec une croissance du revenu limitée à 0,5 %. Notons que si le taux de croissance du revenu atteint 10 % par an, le TRI s'envole et atteint 28,9 % : une bonne affaire pour le fonds !

Dans cet exemple, le « levier » est égal à 450/250, soit 1,8. Pour 1 € de capital investit, 1,80 € de dettes sont levées. En matière d'acquisition immobilière au travers d'une SCI, le levier est plus souvent de 10 lorsque l'associé finance les frais d'acquisitions mais peut être de 1 000 (1 million emprunté pour 1 000 € investi) voire plus encore, si la banque finance à 110 %, frais inclus.

Sauf à accepter de valoriser l'usufruit des parts de la SCI à un taux excessivement voire anormalement élevé, il semble indispensable en réalité de remettre en question l'hypothèse de départ qui veut qu'une SCI au capital de 1 000 € a une valeur en pleine propriété de 1 000 €.

Cette valeur de 1 000 € n'est autre en effet que la valeur patrimoniale (ou valeur mathématique) de la SCI, et la valeur patrimoniale n'est pas la valeur vénale. Comme pour toutes les sociétés, il convient donc de reconnaître que la valeur de la SCI est « la somme de tout l'argent qu'elle gagnera dans le futur ». Dit autrement, la valeur de la SCI est la somme actualisé des flux futurs à l'infini, méthode de valorisation des DCF, seule méthode à même de donner une valeur pertinente, de marché et donc une valeur vénale de la pleine propriété d'une SCI.

Ne pas accepter que la valeur d'une SCI au capital de 1 000 € détenant un bien immobilier intégralement financé par emprunt ne vaut plus 1 000 € dès que la porte du notaire ayant enregistré l'acte authentique est franchie, c'est accepter une hypothèse en vérité inacceptable : que la valeur de l'usufruit, calculé par actualisation des cash-flows prévisionnels à un taux « raisonnable » ou « normal » soit supérieure à la valeur de la pleine propriété. C'est surtout commettre une erreur de raisonnement en acceptant de comparer d'un côté une valeur de rendement, méthode DCF, avec une VAN déterminé selon une valeur patrimoniale. La cohérence implique de déterminer la valeur de l'usufruit et de la pleine propriété selon la même méthode : par actualisation des cash-flows.

515

La conclusion s'impose désormais d'elle-même : il n'est pas possible d'actualiser les flux d'une SCI au TRI compte tenu du fait qu'on ne connaît pas la valeur de la pleine propriété de la SCI.

Si on accepte cette évidence, force est de rechercher un taux différent du TRI de l'investissement.

Deux solutions sont alors possibles : chercher un taux externe ou retenir le taux de rendement du sous-jacent, le taux de rendement de l'immeuble.

Pour Thuran Jouno (op.cit.) « le taux d'actualisation à retenir lorsque les droits démembrés sont ceux d'une SCI ne correspond pas à la somme pondérée du rendement locatif brut des biens qu'elle détient. Dès lors qu'il s'agit d'actualiser des dividendes (ou des dividendes minorés de l'impôt à payer par l'associé), il nous semble que le taux à appliquer est le coût des capitaux propres (Kcp), et non pas d'ailleurs le « wacc », qui prend aussi en compte le coût de l'endettement net. Précisons qu'il est habituel de calculer le coût des capitaux propres selon la formule du modèle d'évaluation des actifs financiers (Medaf ; Capm en anglais). Mais cette formule, qui, même appliquée à des sociétés cotées, induit pour le praticien des difficultés bien documentées, donne selon nous pour des sociétés non cotées des résultats qu'il sera toujours aisé de contester, tant les postulats retenus par l'évaluateur ont d'incidence sur le taux d'actualisation qu'il cherche à calculer ».

Nous partageons cette dernière remarque. L'arbitraire est la règle lorsqu'on cherche à construire un taux en s'appuyant sur des éléments de marché externe.

Ainsi, comment comprendre que la cour administrative d'appel de Nantes retienne, d'une part, le 15 février 2018 un taux de 5 % correspondant « au bas de la fourchette comprise entre 5 % et 7 % habituellement retenue […] par agrégation, d'une part, d'un taux couvrant l'inflation et le coût du temps par référence au taux du marché des emprunts et, d'autre part d'une prime de risque » et, d'autre part, le 31 mai 2018 un « taux d'actualisation de 8 % intégrant un taux sans risque et une prime de risque » tout en rajoutant « l'indexation du loyer sur l'indice du coût de la construction évaluée à 1,5 % par an sur l'ensemble de la période, sans que ce taux se confonde avec celui de

l'inflation » ? Ainsi, à deux mois et demi d'écart, le taux d'actualisation, pourtant parfaitement justifié dans les deux cas par référence au marché, est fixé par la cour à 5 %, inflation comprise, puis à 8 % + 1,5 %, soit près du double ! Le peu de vraisemblance d'une évolution aussi significative des conditions de marché entre le 15 février et le 31 mai 2018 démontre la difficulté de construire un taux en s'appuyant sur des éléments de marché externe.

Retenir le taux de rendement du bien pour actualiser les flux de trésorerie futurs est en tout état de cause la méthode qui ouvre le moins la porte à l'arbitraire et donc à même de sécuriser les contribuables. Cependant, ce n'est pas la difficulté qu'il y a à approcher un taux de rentabilité externe qui doit disqualifier cette approche...

D'autres arguments militent pour retenir le taux de rendement interne du bien pour actualiser les flux de trésorerie de la SCI (contra Th. Jouno, op. cit.).

En premier lieu, c'est la méthode qui se rapproche le plus de celle préconisée par le Conseil d'État : rechercher le même taux de rendement interne pour l'usufruitier et le nu-propriétaire. Or, retenir un taux de marché indépendant du taux de rendement du bien reviendrait en pratique à valoriser l'usufruit à un taux qui pourrait être différent de celui du nu-propriétaire dont le rendement réel, au-delà de la période de remboursement de l'emprunt, sera in fine celui de rendement du bien.

En second lieu, le taux de rendement du bien n'est-il pas en réalité le taux de marché afférent à ce bien, tenant compte de ces spécificités (localisation, état du bien...) et de l'appétence des investisseurs pour ce type d'investissement ? Ainsi, il n'est pas rare de voir des rendements locatifs de l'ordre de 3 % à 4 % sur les marchés d'immeubles parisiens (en raison de leur rareté) tandis que les rendements locatifs de locaux commerciaux atteignent plutôt 7 % ou 8 %. Le taux de rendement du bien traduit en réalité le taux du marché de ce bien incluant de manière implicite un taux sans risque couvrant l'inflation et une prime de risque spécifique à ce bien.

Enfin, la méthode consistant à rechercher un taux de rendement externe est incontournable lorsqu'il s'agit d'actualiser les flux d'une entreprise parce qu'il n'existe pas de taux de rendement interne au sous-jacent. S'agissant d'une SCI, la situation est fondamentalement différente ; la SCI détient un bien unique générant une rentabilité interne facile à identifier. La situation n'est donc pas comparable sur cet aspect. Actualiser les flux d'une SCI, c'est bien actualiser les flux d'une entreprise, mais d'une entreprise particulière qui détient un actif isolé présentant sa propre rentabilité interne.

En l'occurrence, qui viendrait contester qu'en application de la décision du Conseil d'État du 24 octobre 2018, un acquéreur de l'usufruit des parts d'une SCI détenant uniquement un bien immobilier, sans dettes, choisisse d'actualiser les flux au taux de rendement interne du bien ?

Ainsi, la méthode DCF lorsqu'elle est correctement appliquée, est la méthode qui permet « d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date ou l'acquisition est intervenue ». Elle respecte l'intérêt économique de l'acquéreur en lui garantissant une succession de flux financiers actualisée au taux de rendement interne du bien acquis par la SCI, sur toute la durée du démembrement et l'intérêt économique du nu-propriétaire qui bénéficie d'une rentabilité de son investissement identique à celle de l'usufruitier.

La jurisprudence et l'administration s'aligne sur cette approche. Dans sa première proposition de rectification relative à l'affaire Luccotel, l'administration avait actualisé les résultats comptables au taux de 5 %. Le nouveau calcul de l'administration soumise à la cour retient cette fois-ci le taux de rendement net de charge usufruitière du bien, soit 9,31 %.

Faut-il y voir l'application de la décision du Conseil d'État du 24 octobre 2018 (CE, 8e et 3e ch., 24 oct. 2018, n° 412322 et 412323 ; Dr. fisc. 2019, n° 6, comm. 141, concl. R. Victor ; RJF 2019, n° 36 ; IP 1-2020, n° 3, V. Streiff) qui détermine comme principe que le taux à retenir pour l'évaluation de droits démembrés doit être « celui qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire » ?

Nous avons déjà listé les nombreux arguments (CAA Nantes, 1re ch., 31 mai 2018, n° 16NT04184 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=16&numero=04184&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/97/62/CETATEXT000036976265.xml&dat05-31). - CAA Marseille, 4e ch., 11 déc. 2018, n° 17MA02433. - CAA Douai, 4e ch., 1er juillet 2019, n° 17DA01029 : RFP 2020, act. 23, veille F. Versailles) qui militent pour ce choix qui présente l'indéniable avantage d'écarter toute subjectivité et tout arbitraire dans le choix du taux.

Que l'administration modifie ses calculs pour s'aligner sur cette méthode nous semble être plus qu'un signe favorable mais bien la reconnaissance de la pertinence de cette approche.

Au surplus, la cour prend la peine de relever ce point pour le valider en précisant que l'administration a appliqué la méthode dite DCF classique « avec un nouveau taux d'actualisation de 9,31 % qui, au demeurant est supérieur au taux initial et qui a été utilisé par la SARL Hôtel-Restaurant Luccotel pour ses propres calculs ». Thurian Jouno chroniquant les dernières jurisprudences des cours administratives d'appel (Th. Jouno, Jurisprudence des cours administratives d'appel : Dr. fisc. 2021, n° 11, chron. 178, spéc. n° 8) considère ainsi que « la cour a, en quelque sorte, « homologué » [ce taux] ».

D. La valorisation de l'usufruit par la seule valorisation des droits financiers permet-elle d'appréhender l'intégralité de la valeur de l'usufruit ?

516

Une dernière interrogation mérite d'être soulevée. Pour Thuran Jouno (Th. Jouno, Acquisition de l'usufruit de droits sociaux à prix minoré : valeur à inscrire au bilan, concl. ss CAA Nantes, 1re ch., 15 février 2018, n° 16NT01325 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=16&numero=01325&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/36/61/00/CETATEXT000036610051.xml&dat02-15), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel, préc.) la méthode DCF présente une limite en ce qu'elle « ne permet de valoriser qu'une seule des facettes de l'usufruit de parts sociales, à savoir le droit au bénéfice des résultats distribués et non mis en réserve. Elle ne permet pas d'appréhender les autres avantages conférés par la détention de l'usufruit, et notamment le pouvoir d'administration du bien que l'usufruit donne à son détenteur ».

Cette remarque fait écho à un article publié en juillet 2012 dans la Revue de droit fiscal (D. Barthélemy, Évaluation économique de l'usufruit : la nécessité d'une approche dualiste : Dr. fisc. 2012, n° 29, étude 379), dans lequel l'auteur, Denis Barthélemy qualifie cette approche « uniciste » de « réductionnisme analytique » en ce qu'elle réalise « un glissement de la définition légale (le droit de jouir des choses sous réserve d'en conserver la substance) à une définition exclusivement financière (le droit de percevoir les revenus) ». Afin de tenir compte de la « substance économique » du bien sans réduire l'évaluation de l'usufruit à sa seule valeur économique, M. Barthélemy propose une méthode « dualiste » qu'il illustre par un exemple simple portant sur l'évaluation de l'usufruit temporaire d'un bien immobilier procurant un revenu net de charges de 6 000 € par an et dont la valeur vénale de la pleine propriété, déterminée par la méthode de comparaison, est supposée être de 200 000 €. En observant « les marchés financiers pour la classe de risque correspondante », un taux d'actualisation de 3,5 % est retenu. La valeur de l'usufruit, déterminée dans un premier temps par actualisation du revenu de 6 000 € au taux de 3,5 % par an sur 10 ans donne une valeur de 49 900 €. La « valeur financière de la pleine propriété » est déterminée par capitalisation de ce revenu au taux de 3,5 % et donne une valeur (V = r/t) de 171 429 €. La valeur financière de l'usufruit représente donc 29,1 % de la valeur financière de la pleine propriété (49 900 / 171 429). Ce rapport de proportionnalité est ensuite appliqué à la valeur de comparaison de la pleine propriété, soit 200 000 €, pour déterminer la valeur de l'usufruit : 200 000 x 0,291 = 58 200 €. M. Barthélemy en conclu qu'il « faudrait de puissants arguments pour retenir la valeur financière uniciste d'usufruit de 49 900 € et non la valeur dualiste de 58 200 € ».

La méthode que nous préconisons consiste à écarter toute référence aux marchés financiers et à retenir comme taux d'actualisation le taux de rendement interne du bien (3 % pour cet exemple). Cette méthode aurait permis d'atteindre une valorisation de l'usufruit de 51 200 € (6 000 € de revenu actualisé à 3 % par an pendant 10 ans), inférieure de 12 % à la valeur de l'usufruit déterminée par la méthode dualiste.

Aussi séduisante que peut apparaître l'idée consistant à dépasser la seule approche financière afin d'intégrer la valeur cachée entre la jouissance d'une chose et la seule perception des revenus qu'elle génère, la méthode préconisée frappe par l'incohérence de ses résultats. Alors qu'il est attendu par l'acquéreur de l'usufruit un rendement financier de 3,5 %, l'auteur de la méthode dualiste propose in fine l'acquisition d'une rente annuelle de 6 000 € sur 10 ans au prix de 58 200 €, soit un rendement interne réduit à 0,55 %. Si les marchés financiers pour cette classe d'actif présentaient un taux de rendement de 4 %, l'application de la méthode dualiste aurait déterminé une valeur financière de l'usufruit de 48 700 €, représentant 32,4 % de la valeur financière de la pleine propriété et une valeur dualiste finale de 64 900 €. Ainsi, l'acquisition d'un

usufruit générant un revenu annuel de 6 000 € par an sur 10 ans aurait coûté plus que la somme des flux non actualisée (60 000 €), l'acquisition présentant dans cette hypothèse un rendement négatif de – 1,4 % par an. Dans la méthode proposée, l'intérêt économique pour l'acquéreur reste un objectif prioritaire, voire même un « puissant argument » : son investissement doit être financièrement rentable, permettant en lui-même de justifier l'intérêt d'une telle opération, au-delà des avantages non valorisés (et non valorisable ?) auquel il pourrait prétendre en sa qualité d'usufruitier en matière de pouvoir politique.

Il n'est en effet et évidemment pas question de nier l'existence de ces droits et de ces pouvoirs que procure la détention de l'usufruit à la société qui l'acquiert. C'est même l'une des raisons essentielles qui l'a motivée à réaliser cette opération : détenir un pouvoir d'administration sur le bien qu'elle occupe supérieur à celui qu'elle avait en n'étant que locataire. Pour autant, lorsqu'on valorise la valeur en pleine propriété du bien par actualisation du revenu, on procède à une évaluation strictement financière de celle-ci, et alors même que les pouvoirs d'un plein propriétaire sont supérieurs à ceux d'un usufruitier, il ne viendrait à l'idée de personne de rajouter un complément de valeur en raison des droits de propriété qu'on détient. Pourquoi l'évaluation d'un usufruit déterminée par actualisation d'un revenu futur serait-elle incomplète quand la même méthode pour déterminer une valeur en pleine propriété donnerait-elle une valeur globale, pleine et entière ?

En réalité, la détention d'un bien procure comme premier avantage le droit d'en percevoir les fruits. On peut ainsi considérer que les pouvoirs d'administration du bien n'ont en réalité comme raison d'être que de garantir au propriétaire la jouissance paisible et durable dans le temps de ce bien ; ils sont ainsi intrinsèquement inclus dans la valorisation financière puisque sans eux, aucune garantie de percevoir les fruits dans la durée n'est envisageable.

Le doyen Aulagnier le répète inlassablement : « À quoi sert de posséder si ce n'est de jouir ? ». Ainsi, il faut voir le démembrement de propriété comme un partage dans le temps des fruits que la propriété procure ; l'usufruitier étant propriétaire des fruits durant un temps limité à son usufruit, qu'il soit viager ou à durée fixe, le nu-propriétaire l'étant de l'extinction de l'usufruit jusqu'à l'extinction de la chose démembrée.

Jean Aulagnier ne dit pas autre chose (V. J. Aulagnier, Pour une approche « franchement » économique du démembrement de propriété : www.aurep.com/newsletters/pour-une-approche-franchement-economique-du-demembrement-de-propriete/.) : « Le fait que le droit de propriété se décompose en deux droits distincts (droit de jouissance et droit de disposer) n'est pas contesté, pour autant nous avons du mal à admettre que ces droits puissent être séparés au point de figurer dans des mains différentes. Nous avons la conviction que ces droits de jouissance et de disposition sont « consubstantiels », au sens d'inséparables, d'indissociables. [...] Nous proposons une autre approche, **franchement économique**, fondée sur la division entre plusieurs mains tant des droits de jouissance que du droit de disposer. Économiquement, financièrement, le démembrement consacrerait simplement une division entre deux personnes, au moins, des utilités, c'est-à-dire, principalement pour des biens frugifères, des revenus futurs prenant en compte leur période de perception. »

Sous cet angle, nul doute que la valorisation exclusive des fruits procurés par le bien suffit amplement et franchement à appréhender l'intégralité de la valeur des droits détenus tant par l'usufruitier que par le futur plein propriétaire.

E. Existe-t-il d'autres méthodes pour valoriser un usufruit ?

517

En matière d'évaluation, tout est affaire d'espèce ! La méthode exposée dans cet ouvrage répond à une problématique précise : valoriser l'usufruit temporaire des parts d'une société civile détenant un immeuble d'exploitation utilisée par l'usufruitier. Dans cette situation, la détention des parts de la société civile, en pleine propriété avant la cession de l'usufruit temporaire et en nue-propriété à l'issue de celle-ci, est entre les mains des propriétaires de l'entreprise exploitante où d'une partie d'entre eux. Il y a donc une communauté d'intérêt et la question du partage de la valeur doit pouvoir être approché de manière la plus objective possible. En outre, ces schémas d'organisation patrimoniale sont généralement mis en place avec une SCI de constitution récente et détenant un seul actif immobilier, objet de l'opération.

D'autres cas de figures méritent une approche différente. L'objectif étant toujours le même : « l'appréciation de la valeur vénale doit être faite en utilisant les méthodes d'évaluation qui permettent d'obtenir un chiffre aussi voisin que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande à la date ou l'acquisition est intervenue ». Le Conseil d'État précise en effet que « Dans le cas de l'acquisition d'un bien en démembrement de propriété, constitue une telle méthode d'évaluation celle qui définit des prix de la nue-propriété et de l'usufruit tels qu'ils offrent le même taux de rendement interne (TRI) de l'investissement pour l'usufruitier et le nu-propriétaire. » D'autres méthodes sont possibles !

1. Des méthodes alternatives à la méthode des DCF

518

Une décision concernant la maison de champagne René Bouché (CE, 9e et 10e ch., 20 mai 2022, n° 449385, SC Ambroise D et M. et Mme D, concl. C. Guibé, note L. Benoudiz) (Annexe 20) a notamment fait planer un doute en laissant entendre que la méthode élaborée et validée dans l'affaire Luccotel pourrait être remise en question et qu'il était notamment envisageable d'actualiser des dividendes sans pour autant qu'ils aient fait l'objet d'un flux effectif.

Le 20 juillet 2009, Mme D, associée de la société civile d'exploitation viticole (SCEV) Champagne René Bouché, a cédé l'usufruit temporaire de 2 000 parts sociales pour une durée de 10 ans au prix de 196 000 € et l'usufruit temporaire de 1 920 parts sociales pour une durée de 17 ans au prix de 233 856 €. L'acquéreur, la société civile Ambroise D soumise à l'impôt sur les sociétés avait été créée quelques années auparavant, en mai 2006, par Mme D et son époux, chacun détenant la moitié du capital de celle-ci. Le capital social de la SCEV d'un montant de 370 000 € est constitué de 8 000 parts sociales, la société civile Ambroise D détenant donc l'usufruit de 3 920 parts, soit 49 %. La détention d'une participation minoritaire est en l'occurrence déterminante en ce sens que les décisions futures de distributions des résultats resteront entre les mains des associés historiques, ce qui, on le verra, interdira en pratique au contribuable de démontrer qu'une évolution de la politique de distribution est envisageable.

On ne connaît pas la méthode initiale de valorisation retenue par les contribuables ni le montant des résultats de la SCEV Champagne René Bouché mais on peut déduire des éléments relevés par les différentes décisions rendues dans cette affaire certains éléments pertinents.

L'évaluation d'un usufruit temporaire doit-elle s'appuyer sur la seule méthode DCF ou une combinaison de méthodes est-elle possible ?

La combinaison de méthodes retenue par l'administration donne une valeur des usufruits sur 10 ans et 17 ans de 331 240 € et de 500 450 €, soit respectivement 69 % et 114 % de plus que l'évaluation des contribuables comme le relève le Conseil d'État en son point 5. On sait également que l'administration a actualisé ces flux en tenant compte d'une progression de 2 % par an au taux de 5,82 %, ce qui nous donne un flux attaché à ces cessions d'environ 41 000 € au titre de la première année. Compte tenu de la prise en compte d'un impôt fictif, le résultat attaché à ces cessions ressort avant impôt fictif à environ 60 000 € ce qui corrobore l'affirmation relevée par la cour d'une valorisation retenue par le contribuable inférieur à trois années pour l'usufruit temporaire de 10 ans (donc inférieur à 65 333 €) et de quatre années pour l'usufruit temporaire sur 17 ans (et donc inférieur à 58 464 €). En retenant ce montant « plafond » de 58 464 € au lieu des 60 000 € résultant de la seule méthode DCF, l'actualisation du flux avec 2 % de croissance et après IS au taux de 33,33 % donne une valeur de l'usufruit temporaire sur 10 ans de 315 418 € et sur 17 ans de 451 710 € soit une variation par rapport aux valeurs retenues par l'administration de 5 % et 10 %.

Ce petit exercice de reconstitution est utile pour noter que la valeur finale déterminée par l'administration et combinant deux méthodes, l'une basée sur l'actualisation des flux futurs et l'autre sur la valeur en pleine propriété des titres à partir de laquelle l'usufruit est déterminé sur une valeur de rendement, donnent une valeur assez proche de la seule méthode basée sur l'actualisation des flux futurs que nous venons d'appliquer. Il est en effet de pratique habituelle pour l'administration d'approcher une valeur par une combinaison de méthode, pratique censée relever la pertinence de la valeur obtenue dans l'hypothèse, évidemment, où les deux approches permettent d'obtenir des montants présentant un écart de faible ampleur.

On l'a dit, on partage les commentaires de Mme Céline Guibé, rapporteur public : « il n'existe pas une seule et unique "bonne" méthode d'évaluation de l'usufruit des titres de sociétés non cotées. Nous l'avons dit, tout est affaire d'espèce ».

En l'occurrence, dans cette affaire, il s'agissait d'évaluer la valeur de l'usufruit temporaire des titres d'une société civile d'exploitation agricole, non soumise à l'impôt sur les sociétés, exerçant une activité économique et disposant d'un historique de résultat. Les différences avec la situation relative à Luccotel sont nombreuses. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la valeur d'un usufruit temporaire portant sur les titres d'une SCI de constitution récente et venant d'acquérir un bien immobilier, il n'existe pas d'historique de résultat, d'historique de pratique d'affectation du résultat, de problématique relative à la rémunération du dirigeant, d'aléas relatif à l'exploitation comparable à celle d'une activité économique et non civile tandis qu'on dispose d'une information déterminante, le taux de rendement réel, de marché, du sous-jacent : l'immeuble inscrit à l'actif et le rendement locatif de celui-ci.

Ainsi, dans cette situation ou dans une situation proche de celle de Luccotel, la « bonne » méthode, où en tout cas celle qui semble la plus applicable avec pertinence, est celle basée sur l'actualisation des flux futurs en retenant les principes dégagés par le Conseil d'État le 30 septembre 2019 et d'ailleurs rappelé en considérant au point 4 de la présente décision. Nul besoin de recourir à une combinaison de méthodes. En effet, dans cette situation, le recours à d'autres méthodes n'améliorerait pas la pertinence des résultats mais rajouterait de l'incertitude et de la complexité. La valeur patrimoniale de la SCI venant d'acquérir un bien immobilier financé par emprunt bancaire et par apport en compte-courant s'avère en effet négative, à hauteur des droits d'enregistrement supportés sur l'acquisition de l'immobilier, tandis que la valeur de rendement ne peut être valablement calculée, faute d'historique et sauf à la déterminer sur la base d'un prévisionnel, ce que fait de manière hasardeuse la cour d'appel d'Orléans (CA Orléans, ch. com., 21 mars 2019, n° 18/00536) chargée d'estimer la valeur en pleine propriété de la SCI LBA dans l'affaire Luccotel (V. L. Benoudiz, L'évaluation d'une SCI par la méthode DCF : tous les flux, rien que les flux ! : Dr. fisc. 2020, n° 2, étude 52 - pour une critique de la méthode utilisée par la cour).

Une combinaison de méthodes est donc possible dès lors que le recours à cette combinaison permet d'obtenir, par deux ou plusieurs approches différentes, une convergence de valeur, ce qui nécessite, si l'on souhaite recourir à des valorisations de la pleine propriété d'une société, l'existence d'un historique permettant de déterminer des valeurs patrimoniales, des valeurs de rendement et/ou de productivité.

Le taux d'actualisation peut-il être un taux externe construit sur l'OAT majorée d'une prime de risque ?

Si le Conseil d'État n'a pas encore eu à se prononcer formellement sur le taux d'actualisation à retenir dans les schémas « Luccotelien », la pratique et les tribunaux tendent à s'accorder sur le taux de rendement du bien (V. L. Benoudiz, Évaluation de l'usufruit par la méthode DCF : rien que les flux et (presque) tous les flux !, note ss CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19NT03876 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=19&numero=03876&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/42/59/05/CETATEXT000042590564.xml&dat 11-30), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel : JurisData n° 2020-021544 ; Dr. fisc. 2021, n° 13, comm. 196, concl. L. Chollet).

Au cas d'espèce de la SCEV, le recours, s'agissant d'une activité économique de production de champagne, à un taux de rendement de l'OAT majorée d'une prime de risque propre à la société ne semble pas critiquable dans son principe dès lors, au demeurant, qu'il apparaît impossible d'y substituer un taux interne de rentabilité faute de connaître la valeur des incorporels (fonds de commerce, marque...) détenus par la société. La situation aurait pu être différente si, concomitamment ou à une date proche de la cession de l'usufruit temporaire, une cession en pleine propriété de titres à un tiers externalisant une valeur de marché de la SCEV avait été réalisée.

Un dividende est-il systématiquement un flux de trésorerie ?

Venons-en à la mise en œuvre de la méthode des DCF au cas d'espèce de la SCEV. Céline Guibé, rapporteur public, expose ainsi la problématique : « Il est d'abord reproché à la cour d'avoir validé la méthode fondée sur l'actualisation des flux de fruits futurs, alors qu'elle était fondée sur un dividende de référence correspondant à la moyenne des dividendes distribués au cours des années précédentes ne tenant pas compte de la trésorerie effectivement disponible. Les requérants indiquent que ces dividendes n'avaient pas été versés en numéraires mais qu'ils avaient été inscrits au crédit du compte-courant des associées de la SCEV, en l'absence de trésorerie suffisante à la clôture des exercices concernés. Mais une méthode tenant compte des distributions inscrites en compte courant d'associé n'est pas, en soi, injustifiée ». Le Conseil d'État suit l'avis de Mme Guibé en validant la position de la cour et en constatant dans son point 6 « qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fonds que, depuis sa création, la totalité des bénéfices de la SCEV était distribuée et appréhendée par les associés, par perception de numéraire ou inscription au crédit des comptes courants d'associés » et qu'ils pouvaient dès lors faire l'objet d'une actualisation.

La décision, au premier abord, peut surprendre un évaluateur, même si un fiscaliste peut y trouver son compte. On sait en effet, comme le rappelle une jurisprudence constante et l'administration dans son (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-40-§ 100-12/09/2012 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/IR/3392-PGP/2012-09-12/data.html#100)) que « l'inscription d'un revenu au crédit d'un compte non bloqué d'un contribuable vaut en principe paiement et entraîne présomption de disponibilité. Toutefois, cette présomption peut être détruite s'il résulte des circonstances de fait que l'intéressé n'a pas été en mesure de disposer des sommes portées en compte ».

Loïc de Maintenant sur Linkedin considère même que le flux a en réalité été appréhendé et reversé : « En second lieu, selon la politique de distribution de la société, il est tout à fait possible pour un vérificateur d'actualiser les dividendes prévisionnels pour leur montant total à partir du moment où ils sont régulièrement inscrits en compte courant, sans que la société acquéreur puisse se plaindre de ce que leur mon-tant aurait dû être plafonné à la trésorerie disponible. Les spécialistes de l'actualisation des flux pourront à première vue être étonnés que la réalité des flux soit ignorée mais le fiscaliste leur fera alors observer qu'un dividende mis en compte courant est un flux mis un instant de raison à disposition de l'associé qui le remet immédiatement à disposition de ladite société [...]. Un double flux qui s'ignore, en quelque sorte mais qui peut coûter cher si on l'ignore [...] ».

Cette position est parfaitement défendable sur le plan juridique car ce ne sont pas les résultats comptables qui sont actualisés mais bien les dividendes votés par l'assemblée. Dans sa décision du 30 septembre 2019, le Conseil d'État ne parle pas de trésorerie disponible mais bien de dividendes en rappelant que « l'usufruitier, conformément à l'article 582 du Code civil qui lui accorde la jouissance de toute espèce de fruits, n'a droit qu'aux dividendes distribués » et que dès lors, « l'évaluation du revenu futur attendu par un usufruitier de parts sociales ne peut avoir pour objet que de déterminer le montant des distributions prévisionnelles [...] ». Ainsi, tenir compte des dividendes votés par l'assemblée est parfaitement en phase avec cette décision car le « revenu futur » est bien acquis à l'usufruitier, s'agissant d'un dividende distribué et non d'un résultat non encore affecté.

Ce qui pose difficulté, en revanche, c'est l'application de la méthode DCF sur des droits acquis et non sur des flux réels. La méthode DCF consiste en effet à actualiser, c'est-à-dire à appliquer, selon le Larousse, « une méthode de calcul économique permettant de comparer un flux monétaire à venir à un flux monétaire présent ».

Dès lors, on a en effet les plus grandes difficultés à accepter qu'il soit possible d'actualiser des flux qui n'en sont pas réellement et qui ne sont qu'une inscription comptable. Dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, il ne viendrait à l'idée d'aucun associé de voter un dividende imposable sans qu'il soit possible de l'appréhender effectivement. Peu de personnes choisissent de payer un impôt sans percevoir le revenu afférent. À l'inverse, dans une société de personnes, le contribuable considère que l'affectation étant sans conséquence fiscale, celle-ci est souvent décidée sans qu'il y soit prêté l'attention qu'une telle décision mérite.

Ainsi, on ne partage pas l'avis du rapporteur public lorsqu'il considère comme « [n'étant] pas, en soi, injustifié » l'application de la méthode DCF en retenant non pas des flux mais des écritures comptables et il nous semble, contrairement à son appréciation considérant comme « non décisive » les circonstances de l'espèce, que celles-ci sont au contraire déterminantes.

Ainsi, Céline Guibé précise « qu'on peut en outre relever, même si la circonstance ne nous apparaît pas décisive, que si une partie importante des distributions avait, effectivement, été inscrite au compte-courant des associés, les sommes correspondantes avaient fait l'objet de retraits réguliers et tout aussi conséquents au cours des exercices en cause. Il n'y avait donc pas lieu de penser que la situation de la trésorerie aurait pu faire obstacle de manière prolongée, à la perception des distributions ».

C'est exactement ce que le relève le Conseil d'État dans son point numéro 6 justifiant la méthode consistant à actualiser les distributions indépendamment de leur perception effective : « En l'absence d'argumentation des contribuables tirée de ce que le montant des distributions prévisionnelles tel que déterminé par le vérificateur serait surévalué en tant qu'il ne prendrait pas en compte certains éléments susceptibles de l'affecter qu'ils étaient seuls en mesure de justifier, notamment le solde de la trésorerie disponible [...] » En l'occurrence, le contribuable a été incapable de démontrer que les dividendes votés chaque année et affectés en compte-courant ne pouvaient pas faire de manière prolongée obstacle à leur appréhension effective. La méthode alternative d'évaluation de l'usufruit qu'il a également proposée n'a pas

résisté à une analyse critique conduite par la cour et entérinée par le Conseil d'État. Le contribuable faisait en effet état de variations de son besoin en fonds de roulement, de besoins d'autofinancement « sans justifier des motifs pour lesquels [il] entendait modifier pour l'avenir sa pratique antérieure constante de distribution de la totalité de ses bénéfices ». En outre, au regard de cette argumentation estimée peu crédible, le Conseil d'État reprend l'argumentation de l'administration qui relève que « la méthode proposée par le contribuable aboutissait sur les quatre années antérieures à retenir un montant de trésorerie disponible nettement inférieur au montant effectivement distribué au titre de ces mêmes années ».

L'administration, la cour et le Conseil d'État auraient-ils dû se livrer à une analyse détaillée des flux de trésorerie pour déterminer au titre de chaque année le montant réel des dividendes effectivement versés alors même que le contribuable en est incapable ? Évidemment que non ! Si le contribuable n'a pas été en mesure de le faire, gageons qu'en réalité les dividendes affectés en compte-courant sont effectivement prélevés par les contribuables l'année même ou rapidement, et en cas de perception décalée, pas « de manière prolongée ».

Le rappel par le Conseil d'État, en considérant de principe, que l'évaluation par la méthode DCF doit « tenir compte des distributions prévisionnelles qui [peuvent]t être fonction notamment des annuités prévisionnelles de remboursement d'emprunt ou d'éventuelles mises en réserves pour le financement d'investissements futurs, lorsqu'elles sont justifiées par la société » est confirmé. Il convient en revanche, lorsque la société met en œuvre une politique de distribution systématique de ses résultats par affectation en compte-courant, qu'elle puisse effectivement démontrer que ces distributions ne sont pas appréhendables immédiatement ou à court terme. Au cas d'espèce, cette démonstration était impossible à faire par le contribuable pour la simple et bonne raison que l'historique des dernières années démontrait au contraire, comme l'a relevé le rapporteur public, que « les sommes correspondantes [faisaient] l'objet de retraits réguliers et tout aussi conséquents ». D'ailleurs, le contribuable n'a pas reconstitué au titre des années précédentes les flux de trésorerie réels pour proposer une évaluation basée sur cet historique mais a tenté d'expliquer, sans réussir à convaincre la cour, que dans le futur, les distributions effectives seront inférieures aux distributions passées.

Au demeurant, faute d'emprunt impactant les cash-flows ou d'affectation en réserve en vue d'investissements futurs, le montant des distributions ne peut être différent des flux de trésorerie que marginalement de telle sorte qu'un décalage d'une ou deux années dans la perception du flux en raison de variations du besoin en fonds de roulement n'aura qu'un impact limité sur la valorisation de l'usufruit temporaire.

La même décision aurait-elle pu être prise si, contrairement aux circonstances de l'espèce relevant une appréhension effective des dividendes à l'occasion de « retraits réguliers » et « conséquents au cours des exercices en cause », les sommes étaient restées en compte-courant sur une longue période, faute de trésorerie disponible pour les appréhender ?

Il ne fait pas de doute que la distribution de dividendes étant votée, ces sommes sont à disposition des associés même si elles sont indisponibles en pratique faute de trésorerie. Il convient donc d'en tenir compte dans l'évaluation du revenu futur contrairement à des résultats qui n'appartiennent pas à l'usufruitier tant qu'une décision d'affectation en dividendes n'a été prise. Pour autant, la cour administrative d'appel de Nantes (CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19NT03876 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=19&numero=03876&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/42/59/05/CETATEXT000042590564.xml&dat 11-30), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel : JurisData n° 2020-021544 ; Dr. fisc. 2021, n° 13, comm. 196, concl. L. Chollet, note L. Benoudiz) écarte la méthode que nous avions proposée pour appliquer correctement la méthode DCF et désignée comme étant la « méthode Benoudiz » consistant à tenir compte des flux futurs selon la date de perception effective de ceux-ci, y compris au-delà de la durée de démembrement.

La motivation de la cour d'appel, suivant les conclusions du rapporteur public Laure Chollet reprenant l'argumentation d'Émilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public lors de la décision du Conseil d'État, consistait à considérer, au-delà d'une certaine durée (et notamment au-delà de la durée du démembrement) qu'il existait trop d'incertitudes sur la perception de ces fruits futurs.

On ne peut qu'être d'accord avec ces remarques et avec la conclusion retenue par la cour administrative d'appel de Nantes. Comme le dit Vivien Streiff, trop d'incertitudes au-delà d'une certaine durée doit conduire à écarter un revenu potentiel « dont on ne sait, eu égard aux multiples aléas qui peuvent affecter la vie de la SCI, quand il apparaîtra, ni même s'il apparaîtra un jour » (V. Streiff, Nouvelles précisions sur la méthode d'évaluation de l'usufruit à durée fixe de parts sociales : Solution Notaire Hebdo, 18 févr. 2021, n° 6, inf. 13).

Il apparaît finalement que la méthode DCF consistant à actualiser les flux sur une longue période apparaît comme trop aléatoire au-delà d'une certaine durée tandis qu'il semble intellectuellement difficile de considérer cet avantage potentiel futur comme nul et non avenu. Une autre piste est-elle envisageable pour tenir compte de ces distributions non appréhendées et non appréhendables à court terme ? C'est possible mais on ne sait pas comment ! Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'il ne pourra pas être question d'appliquer à des écritures comptables d'affectation en dividendes une actualisation devant s'appliquer, par principe, à des flux sous peine d'appliquer la méthode DCF de manière viciée. Quand bien même l'affectation en dividendes serait juridiquement une mise à disposition, elle n'est pas et ne peut être un flux de trésorerie pouvant faire l'objet d'une actualisation.

Émilie Bokdam-Tognetti ne dit pas autre chose dans ses conclusions devant le Conseil d'État et il nous semble nécessaire de citer intégralement sa conclusion : « Si la première solution - ne pas assimiler dividende distribuable et trésorerie disponible et tenir compte, au sein des flux futurs de trésorerie de l'usufruitier, d'une possibilité de distribution d'un dividende supérieur aux disponibilités en banque de l'entreprise avec versement du numéraire plusieurs années après - est la plus sophistiquée et sans doute la plus intellectuellement séduisante, elle nous paraît se heurter à trop de difficultés. D'abord, si elle est juridiquement possible, il peut sembler douteux qu'une telle pratique de distribution puisse être systématique en cas de décalage d'ampleur entre la trésorerie et le bénéfice comptable. Elle dépend en outre de la probabilité même que la trésorerie permette un jour un tel remboursement. Sa prise en considération dans la valorisation de l'usufruit dépendra enfin de l'horizon temporel dans lequel le retour sur investissement est exigé. La solution inverse consistant à ne prendre, pour calculer les flux de trésorerie que générera la détention de l'usufruit des titres, que le montant du bénéfice distribuable dans la limite de la trésorerie effectivement disponible a, par contraste, le mérite de la simplicité. Point n'est besoin de reconstituer à quelle date il est prévisible que la trésorerie permettra - compte tenu des autres engagements de la société (tels que des avances en compte courant consenties par d'autres associés) - de rembourser tout ou partie des dividendes inscrits sur le compte courant de l'usufruitier, ni de s'interroger sur la rémunération de ce compte courant, ni enfin de se lancer dans l'exercice délicat de détermination (sinon d'imagination, en l'absence d'historique) de ce que pourra être la sensibilité de la politique effective de distribution de la société à l'état de sa trésorerie. Dès lors, même si elle conduit à omettre une partie de l'avantage économique potentiel lié à l'usufruit, elle nous semble plus praticable et, par suite, préférable. Mais, que ce soit par un plafonnement définitif du montant des distributions annuelles prises en compte dans les fruits, ou par une perception différée (pénalisée par le coefficient d'actualisation) d'une partie des dividendes, la situation de trésorerie de l'entreprise ne peut en tout état de cause être ignorée pour évaluer directement la valeur financière d'un usufruit ».

Dès lors, c'est bien au regard des circonstances de l'espèce, en raison d'un décalage temporaire d'une durée de faible ampleur, qu'il est possible d'assimiler la distribution de dividendes à la perception effective des revenus et d'y appliquer, sans vicier la méthode, une actualisation temporelle. Il n'en est pas de même, comme le relevait le rapporteur public Laure Cholet (concl. L. Chollet ss CAA Nantes, 1re ch., 26 nov. 2020, n° 19NT03876 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CAA&ville=NT&annee=19&numero=03876&sp=/jade/global/inedit/CETA/TEXT/00/00/42/59/05/CETATEXT000042590564.xml&dat 11-30), SARL Hôtel-Restaurant Luccotel : Dr. fisc. 2021, n° 13, comm. 196, note L. Benoudiz), suivie par la cour, lorsqu'il existe « un décalage d'ampleur entre la trésorerie et le bénéfice comptable dans le temps et, d'autre part, un report du versement du solde des distributions en fonction de la trésorerie à une date indéterminée ». Or, au cas d'espèce, nul décalage d'ampleur et nulle incertitude sur la perception effective des distributions votées par l'assemblée de la SCEV.

Enfin, il nous semble utile de rappeler que, lorsque le Conseil d'État prend la peine de préciser que les flux à retenir dans la méthode DCF doivent tenir compte des annuités de remboursement d'emprunt et des mises en réserves « lorsqu'elles sont justifiées par la société », il est nécessaire de pouvoir en effet en justifier ! Or, procéder chaque année à une distribution intégrale des résultats par inscription en compte-courant « entraîne présomption de disponibilité » (BOFiP-IR-BASE-10-10-10-40-§ 100-12/09/2012 (/lien_bofip/?base=BOFiP&mode=article&orig=REVUE_RF_FH&sp=/Commentaire/IR/3392-PGP/2012-09-12/data.html#100)). On peut également rajouter que cela entraîne présomption de perception effective et qu'il n'est pas du ressort de la cour d'aller chercher chaque année quels sont les flux effectivement perçus par les associés. À charge aux contribuables de n'affecter les résultats en dividendes qu'avec parcimonie et à bon escient.

2. La remise en question de l'égalité U+NP=PP

519

Des opérateurs proposent désormais à des investisseurs l'acquisition d'usufruits temporaires ou de nue-propriété sans que les acquéreurs soient liés entre eux, comme de purs produits de placement. La valeur de l'usufruit temporaire est ainsi déterminée par rapport au marché, aux taux de rendement de produits présentant un profil de risque identique et une fiscalité comparable.

Il s'agit bien souvent de biens immobiliers ayant fait l'objet de travaux de rénovation et dont le rendement locatif permet d'évaluer la valeur de l'usufruit d'un coté et la valeur de la nue-propriété de l'autre à un total supérieur à la valeur de la pleine propriété du bien. En outre, la fiscalité étant différente pour l'investisseur en usufruit et pour l'investisseur en nue-propriété (absence d'IFI, d'impôt sur le revenu, de taxe foncière), le rendement attendu de l'un et de l'autre sont souvent très différents. L'usufruit locatif social (ULS) en est un bon exemple.

Comment concilier ainsi une approche, validée par le marché, d'une valorisation d'un usufruit indépendante de la valeur de la pleine propriété d'une valorisation respectant les principes dictés par le Conseil d'État ?

À notre avis, la valeur de l'usufruit dépend en réalité du contexte de l'opération. S'il s'agit de découper dans le temps la propriété d'un bien en transmettant durant une période temporaire les revenus, les droits et les pouvoirs d'administration à une société contrôlée, l'équilibre dans le partage doit être la règle. À l'inverse, si l'usufruit devient un pur produit d'investissement, sa valorisation doit être déterminée indépendamment du rendement potentiel attendu par le nu-propriétaire, sur la base de sa seule valeur de marché. En quoi une telle distinction a-t-elle du sens ? En pratique, on a d'un coté un usufruit dont l'acquisition est envisagée en raison des avantages politiques qu'il octroi à son propriétaire alors que l'opération porte à l'inverse sur un seul composant : le rendement financier procuré par l'investissement. Les droits de l'usufruitier sont dans cette hypothèse généralement limité à la seule perception des revenus. Cette approche purement financière conduit l'investisseur à n'examiner que le rendement estimé probable, sans tenir compte d'autres avantages politiques que lui confère cette détention. On n'achète pas en réalité la même chose, ce qui conduit à les évaluer différemment.

Prenons l'exemple d'un bien d'une valeur en pleine propriété de 100 000 € qui génère un revenu annuel de 4 % sur les 15 prochaines années. La valeur de l'usufruit selon méthode Aulagnier consistant à actualiser sur les 15 prochaines années un flux de 4 000 au taux de 4 %, taux de rendement du bien, donne une valeur de 44 474 € pour l'usufruit.

Si je me positionne en tant qu'investisseur et que j'escompte un rendement cible de 6 %, le prix que je serais disposé à payer pour l'acquisition de cet usufruit serait de 38 849 €, soit avec une décote de 12,6 % (un investissement de ce montant générant un revenu annuel de 4 000 € pendant 15 ans présente un TRI de 6 %).

N'ayant aucun autre intérêt que financier dans cette opération, la valeur de l'usufruit se trouve réduite afin de maximiser sa rentabilité.

À l'inverse, quel signal enverrait un usufruit cédé plus cher que sa valeur intrinsèque déterminée par rapport à la valeur de la pleine propriété ? À l'évidence, qu'il s'agit d'une opération ayant permis d'obtenir un rendement cible supérieur aux attentes du marché et qu'il est ainsi possible de valoriser l'usufruit, en tant que produit de placement, à un montant supérieur compte tenue de la rentabilité réelle du bien.

F. La durée

520

L'usufruitier peut être une personne morale ou une personne physique. On sait que l'usufruit, même constitué pour une durée déterminée, cesse obligatoirement à la disparition de la personne sur la tête de laquelle il a été constitué, et ce, qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale.

1. L'usufruit constitué sur la tête d'une personne physique

521

L'usufruit à durée fixe constitué sur la tête d'une personne physique cesse automatiquement en cas de décès de celle-ci (cass. civ. 16 juin 1933, DH 1933.393).

Il en résulte une incertitude sur la durée de l'usufruit. En effet, cette dernière dépendra de l'espérance de vie de l'usufruitier (ou du couple usufruitier) sur la période considérée, qui sera elle-même fonction de son âge au moment de la création de l'usufruit. En effet, l'espérance de vie se calcule à chaque âge.

Toutes choses égales par ailleurs, un usufruit temporaire détenu par une personne physique a donc une valeur statistique inférieure au même usufruit appartenant à une personne morale (qui, par hypothèse ne peut pas mourir).

EXEMPLE

La formule de calcul de l'espérance de vie est la suivante (J.-P. Landrieu : Calculs mathématiques dans la gestion de patrimoine, éd. Maxima, 1996).

$$e(x) = \frac{1}{2} + \frac{\sum S(k)}{S(x)} \text{ (k variant de x + 1 à n)}$$

(20190730150406293_2.jpg)

Où :
-e (x) : espérance de vie
-S (k) : nombre de survivants de 1 à n (période de l'usufruit considérée)
-S (x) : nombre de survivants à l'âge n

Selon les dernières tables de mortalité (http://www.ined.fr), l'espérance de vie d'un homme de 60 ans sur les 10 ans à venir est de 8,95 ans. La valeur d'un usufruit constitué sur sa tête doit donc être actualisée sur cette durée et non sur 10 ans.

2. L'usufruit constitué sur la tête d'une personne morale

522

Sauf dissolution anticipée ou fusion de la société par absorption, la durée de l'usufruit stipulée est certaine. Aussi, l'actualisation s'opérera-t-elle sur la durée constituée. Au terme prévu, l'usufruit s'éteindra (c. civ. art. 617 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=617&idspad=LEGIARTI000020616161)).

La durée maximum assignée par la loi pour les usufruits détenus par les personnes morales est de 30 ans (c. civ. art. 619 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=619&idspad=LEGIARTI000006429628)). Ce texte est d'ordre public (cass. civ., 3e, 7 mars 2007, BC III n° 36 ; RJDA 7/07, n° 793). On ne pourra donc stipuler contractuellement une durée supérieure.

3. La constitution d'usufruit

523

L'usufruitier étant propriétaire de son usufruit, la cession de celui-ci est définitive pour le disposant (R. Libchaber : Une cession temporaire d'usufruit ?, Defrenois 2008, n° 15, p. 1656). Si l'usufruitier souhaite consentir un usufruit pour une durée déterminée à un tiers et en retrouve les prérogatives au terme prévu, il lui faudra alors consentir un usufruit sur l'usufruit possédé (sur l'ensemble de la question, M. Iwanesko : Usufruit d'usufruit, in Qu'en est-il de la propriété, l'appropriation en débat, Actes du colloque de l'Institut Fédératif de la Recherche, 27 et 28 octobre 2005, Presses de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse ; Droit et Patrimoine 05/2006).

Ce procédé est jugé valide par la doctrine (A. Rieg, Encyclopédie Dalloz, Usufruit, nos 102, 181 et 278 ; Planiol : Traité élémentaire de droit civil par Rlipert et Boulanger, T. I, n° 3513 : Aubry et Rau, T. II, n° 416). L'objet du second usufruit n'est rien d'autre que le droit d'usufruit du premier titulaire (F. Barbier : La nature juridique de l'usufruit, Thèse Lyon 1987, p. 198).

Les droits des deux titulaires sont en tous points semblables. L'usufruitier d'usufruit profite alors de toutes les prérogatives dont disposait le constituant (Aubry et Rau, précités, n° 416), la valeur de l'usufruit d'usufruit est alors égale à la valeur de l'usufruit. Mais il n'est pas usufruitier mais seulement cessionnaire de l'usufruit. *« … Son bénéficiaire (L'usufruitier d'usufruit) n'est pas titulaire du droit incorporel objet de son droit. Il n'en a que l'exercice, parce que la possession d'un droit n'est autre que son exercice. L'usufruitier de la chose et l'usufruitier de l'usufruit, au fond, se « partagent » l'usufruit, non pas par une répartition des attributs, mais par une ventilation des dimensions du droit : l'un a le titre, l'autre l'émolument »* (F. Zenati, Droits de l'usufruitier, RTD civ. 1998, p. 414). L'usufruitier initial ne pouvant disposer de plus de droits qu'il n'en possède, aussi, les droits du second usufruitier consistent-ils en l'usage et les fruits du premier usufruitier (F. Barbier, Thèse précitée, p. 199).

a) Le constituant usufruitier est une personne physique

524

Au terme stipulé, si l'usufruitier en titre existe toujours, il recouvrera toutes les potentialités de l'usufruit.

En revanche son décès entraînera la fin de l'usufruit qu'il possède et par voie de conséquence l'usufruit qu'il aura consenti, l'usufruit cessant nécessairement avec le décès de la tête de celui sur lequel il a été initialement constitué (Ch. Réunies, 16 juin 1933, DH 1933, 393).

Enfin, si l'usufruitier d'usufruit décède avant le terme stipulé et si l'usufruitier initial est vivant, l'usufruit d'usufruit cessera et l'usufruitier initial retrouvera le plein exercice de son usufruit (S. Grimaldi : Le caractère viager de l'usufruit, Thèse Paris II, 2000, p. 103).

Il en résulte le risque pour l'usufruitier d'usufruit de voir son droit disparaître en cas de décès de l'usufruitier constituant. Afin de sécuriser l'opération, il conviendra alors de faire constituer un usufruit successif sur la tête de l'usufruitier d'usufruit par le nu-propriétaire. En cas de décès de l'usufruitier initial, l'usufruit successif s'ouvrira et l'usufruitier d'usufruit aura alors la certitude de jouir de l'usufruit pour la durée stipulée.

Le propriétaire (ou le nu-propriétaire : Req. 15 mai 1865 ; DP 1865.1, p. 431 ; cass. civ., 1re, 25 octobre 1978, JCP N 1980, T. II, p. 278, obs. Thuillier ; H. Thuillier : La transmission à cause de mort de l'usufruit d'un bien n'appartenant au défunt qu'en nue-propriété, JCP N 1975, T. I, n° 2694) peut en effet créer plusieurs usufruits qui s'ouvriront successivement, si du moins l'usufruitier en second est vivant le jour du décès de l'usufruitier initial.

La valeur de cet usufruit est égale à la valeur actualisée des revenus usufructuaires sur la durée résiduelle entre la durée de l'usufruit concédé et la durée fixe stipulée.

La formule de calcul de l'usufruit successif est la suivante :

$$U_2 = \frac{R \times \left[(1+i)^{Ev^2 - Ev^1} - 1\right]}{i \times (1+i)^{Ev^2}}$$

(20190730150406293_3.jpg)

Si toutefois, on souhaitait créer un usufruit de durée supérieure, il conviendrait de faire consentir un usufruit successif par le propriétaire (avant le démembrement initial) ou par le nu-propriétaire (après le démembrement) dont la valeur résulte de la formule suivante.

Où :

-U2 = Valeur de l'usufruit successif

-Ev1 = espérance de vie de l'usufruitier initial

-Ev2 = espérance de vie de l'usufruitier successif

-R = revenu net de charges usufructuaires

-i = taux d'actualisation retenu

EXEMPLES

1

M. Jeannot Lagnier est titulaire d'un usufruit viager par suite de la donation de la nue-propriété qu'il a consentie à son fils. Son espérance de vie est par hypothèse de 15 ans. Il souhaite constituer un usufruit de 10 ans sur l'usufruit qu'il possède au profit d'une société. La valeur de l'usufruit qu'il cède dépendra donc de son espérance de vie sur dans les 10 ans à venir. Pour assurer à la société acquéreur la détention d'un usufruit pendant la période considérée il conviendra de faire consentir un usufruit de 10 ans par le nu-propriétaire, dont la valeur sera déterminée grâce à la formule ci-dessus. Si l'espérance de vie de Jeannot Lagnier est de 8 ans, la valeur de l'usufruit consenti par le nu-propriétaire sera donc égale à l'actualisation du flux de trésorerie des années 9 et 10.

2 M. Jean Tillome constitue un usufruit d'usufruit de 10 ans au profit de M. Jean Porte. Ce dernier a 60 ans. Son espérance de vie les 10 ans à venir est de 8,95 ans. Pour assurer à Jean Porte qu'il jouira de 10 ans d'usufruit, le nu-propriétaire lui consentira un usufruit successif de 10 ans, dont la valeur sera calculée par actualisation du flux de revenu pendant 1,05 ans des années 8,95 à 10.

b) Le constituant usufruitier est une personne morale

525

Si le constituant de l'usufruit d'usufruit est une personne morale, il n'en résultera pas d'aléa de durée pour l'usufruitier d'usufruit (sauf dissolution ou fusion, voir § 150) si la durée de l'usufruit constitué est inférieure ou égale à l'usufruit initial.

Chapitre II - Les particularités du barème fiscal

526

Le recours au barème fiscal édicté à l'article 669 du CGI est obligatoire pour la détermination de l'assiette :

-des droits de mutation à titre gratuit,

-des droits d'enregistrement,

-de la taxe de publicité foncière,

-des plus-values immobilières,

-des droits dus à raison du dénouement des contrats d'assurance-vie dont la clause bénéficiaire a été démembrée.

La réponse ministérielle Groskosst (JOAN, 28 juin 2005, p. 6466) a confirmé que le recours au barème de l'article 669 du CGI est obligatoire pour la détermination de l'assiette des droits de mutation. Interrogé par un parlementaire sur l'application du barème fiscal pour les liquidations de droit d'enregistrement, le ministre a répondu que *«... pour la liquidation des droits de mutation... l'administration fiscale retiendra la valeur telle qu'elle résulte de l'application du barème non seulement lorsque le prix stipulé sera inférieur à la valeur vénale, mais aussi lorsqu'il sera supérieur ».*

Par dérogation au principe édicté par l'article 666 du CGI, l'impôt n'est donc pas assis sur le prix ou la valeur vénale, mais sur une valeur déterminée forfaitairement par l'administration.

En revanche, l'article 669 du CGI ne vise pas la TVA. L'assiette de cet impôt reste donc déterminée par l'article 266-2-b du CGI :

« 2. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

...

b. Pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

Le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent... ».

Par ailleurs, il convient d'observer que l'évaluation fiscale de l'usufruit ne peut être utilisée en droit des sociétés. L'usufruit doit être immobilisé pour sa valeur vénale [art. 38 quinquies (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=38%20quinquies&idspad=LEGIARTI000020058589), de l'annexe III du CGI : *« Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend :*

Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (...)

Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport ; (...) »)].

En effet, les immobilisations doivent donc être évaluées pour leur coût à la date de leur entrée dans l'actif et il s'agit d'une constatation et non d'une décision de gestion (CE 4 novembre 1970, n° 77759 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=77759&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/07/61/33/CETATEXT000007613310.xml&date=1970-11-04), : Dupont 1971 p. 35 ; CE 7 janvier 1977, n° 96999 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CE&numero=96999&sp=/jade/global/publie/CETA/TEXT/00/00/07/61/60/CETATEXT000007616033.xml&date=1977-01-07), : RJF 3/77, n° 125). Or, on sait que l'administration peut écarter l'évaluation d'un élément d'actif si elle le considère exagéré ou insuffisant (CE 28 mars 1979, n° 1772 : RJF 5/79 n° 273, Dr. Fisc. n° 6/80, comm. 271, concl. D. Fabre).

Chapitre III - La structuration juridique de l'opération de démembrement

527

La question de la localisation de l'usufruit lors de l'opération doit être soigneusement analysée, eu égard, notamment, à la particularité juridique de l'usufruit.

En effet, ainsi que nous l'avons préalablement indiqué, lorsque l'usufruit est constitué sur la tête d'une personne, le décès de cette dernière s'il s'agit d'une personne physique, sa dissolution ou son absorption s'il s'agit d'une personne morale entraîne sa disparition automatique sans qu'il soit possible d'en proroger la durée.

Il est donc vivement déconseillé de créer l'usufruit sur la tête d'une personne physique et on lui préférera une personne morale, au besoin créée ad hoc.

De la même manière on évitera de localiser l'usufruit dans une société opérationnelle susceptible d'être fusionnée dans le futur. En effet, comme nous l'avons exposé ci-dessus (voir § 337 (20151105103652284.html#337)), l'opération de fusion étant juridiquement équivalente au décès d'une personne physique, l'usufruit disparaîtrait en cas de fusion.

I. Les différents détenteurs de l'emprunt

A. L'entrepreneur individuel

528

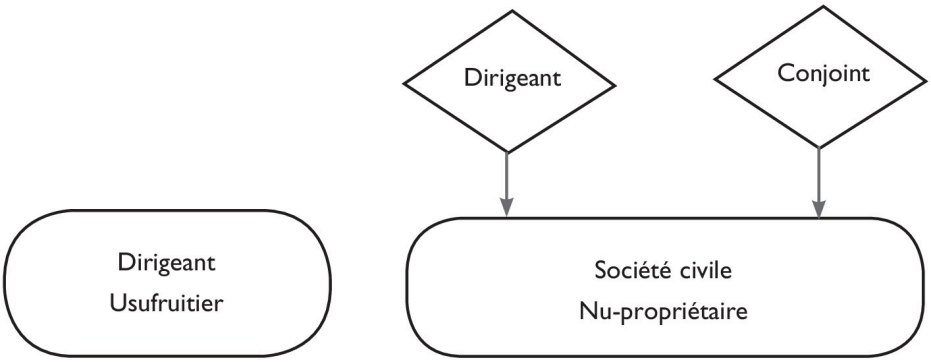
Il s'agit ici d'un investissement immobilier par un entrepreneur individuel ou un professionnel libéral exerçant en nom propre.

L'usufruit étant un droit de jouissance sur la chose d'autrui (c. civ. art. 578 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=578&idspad=LEGIARTI000006429233)), il n'est pas possible de constituer un usufruit sur sa tête si l'on est propriétaire du bien en cause, ce qu'illustre l'adage *nemini res sua servit* (une chose ne peut vous servir de servitude, mais elle est utile à titre de propriété).

Il faudra alors constituer une personne morale qui sera titulaire soit de l'usufruit, soit de la nue-propriété, selon la voie que l'on aura choisie.

1. Usufruit acquis par l'entrepreneur et nue-propriété logée dans une société civile ad hoc

529



(20190730150406293_4.jpg)

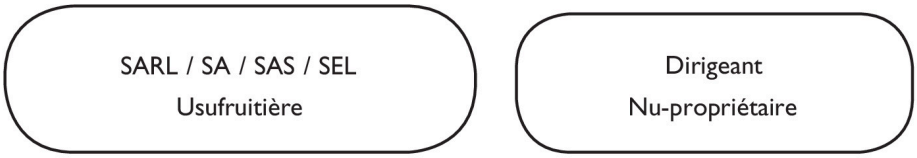
Cette solution présente l'avantage de la simplicité. Le dirigeant conserve le régime fiscal qui lui est propre (BIC, BNC...).

Les inconvénients sont de plusieurs ordres :

Il faut constituer une société civile et donc trouver un second associé. Le dirigeant n'a donc pas la maîtrise totale de l'opération. Par ailleurs, la constitution de la société civile et la tenue de sa comptabilité entraînent des frais.

2. Apport de l'activité à une société sous le régime de l'article 151 octies du CGI qui achète l'usufruit, la nue-propriété étant acquise en direct par le dirigeant

530



(20190730150406293_5.jpg)

Cette solution oblige à constituer une société destinée à l'activité, ce qui peut entraîner un changement de régime fiscal.

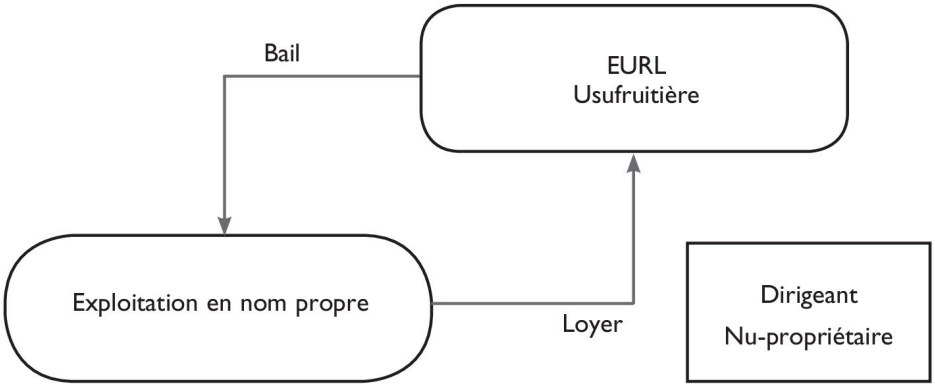
L'avantage réside alors dans le fait que le dirigeant peut autant contrôler seul la société et acquérir seul la nue-propriété.

Observons qu'il résulte de ce schéma une neutralité totale en termes d'ISF, mais pas forcément en matière d'IFI.

3. Constitution d'une EURL usufruitière ; bail à l'exploitant en nom propre ; dirigeant nu-propriétaire

531

Ce schéma pourra être mis en place pour le dirigeant qui souhaite continuer à exploiter en nom propre et qui entend maîtriser totalement l'immeuble.



(20190730150406293_6.jpg)

B. L'exploitation en société

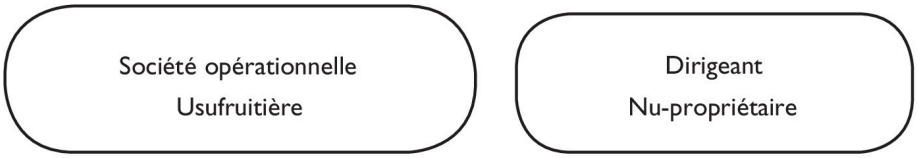
532

Au gré des besoins et selon les circonstances, on sera amené à localiser l'usufruit soit dans la société opérationnelle, soit dans la holding, soit encore dans une société foncière créée ad hoc.

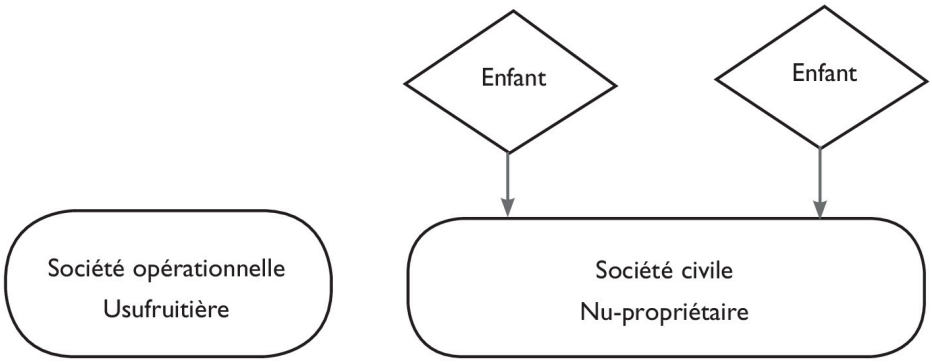
1. Usufruit acquis par la société opérationnelle, nue-propriété acquise en nom propre ou dans une société civile

533

Il pourra utilement être recouru à cette solution pour les petites entreprises non destinées à être cédées en cours d'usufruit et insusceptibles d'être fusionnées.



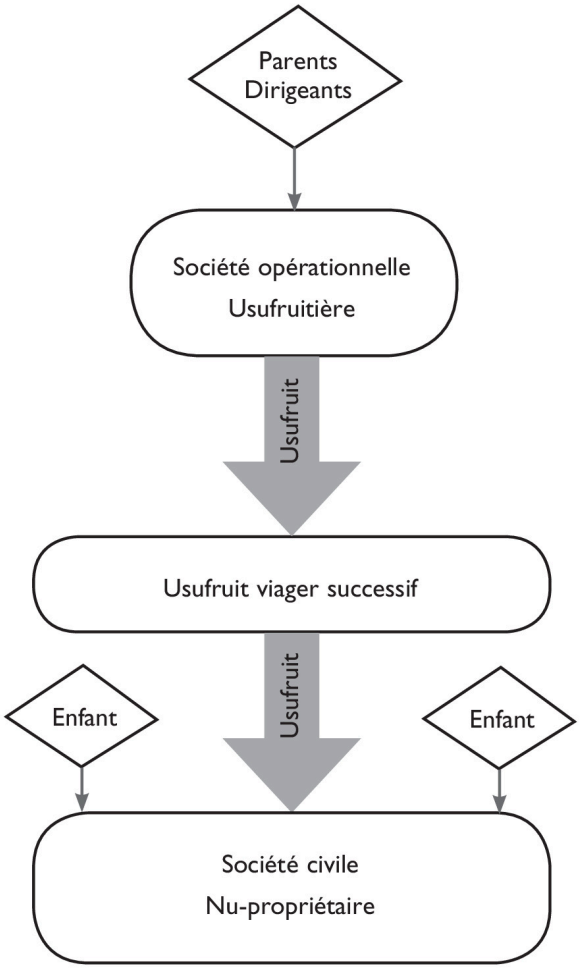
(20190730150406293_7.jpg)



(20190730150406293_8.jpg)

En fonction de son âge le dirigeant pourra souhaiter y coupler une opération de transmission de patrimoine.

Il suffira alors qu'il donne les liquidités à ses enfants, ces derniers achetant alors la nue-propriété. Afin d'éviter les aléas de l'indivision entre eux, on aura recours à une société civile.



(20190730150406293_9.jpg)

Si le dirigeant souhaite pouvoir retrouver les revenus fonciers au terme de l'usufruit, il pourra acquérir la nue-propriété dans une société civile qu'il aura constituée avec son épouse. Ils donneront alors la nue-propriété des titres à leurs enfants tout en se réservant un usufruit successif. La Cour de cassation a en effet précisé que le propriétaire d'un bien grevé d'un usufruit conservait la faculté d'en disposer librement sous la seule condition de respecter l'usufruit en cours et qu'il pouvait concéder sur cet immeuble un second usufruit dont la jouissance ne commencera qu'à l'époque où celle du premier aura pris fin (Req. 15 mai 1865, DP 1865.1, p. 431). Cet arrêt a été confirmé depuis (cass. civ., 1re, 25 octobre 1978, BC I n° 324 ; JCP N 1980, II, p. 278, obs. Thuillier, sous le même attendu : « Mais attendu que le propriétaire d'un immeuble grevé d'un usufruit conserve la faculté d'en disposer librement sous la seule condition de respecter le droit essentiellement temporaire ou viager de l'usufruitier ; qu'il peut notamment conserver sur cet immeuble un usufruit sauf à ce que la jouissance du second usufruit ne commence qu'à l'époque où celle du premier aura pris fin… ») .

Un propriétaire peut ainsi donner la nue-propriété d'un bien tout en se réservant un usufruit successif qui s'ouvrira au terme de l'usufruit initial, si l'usufruitier est vivant à ce moment-là (sur le mécanisme juridique, voir H. Thuillier, La transmission à cause de mort de l'usufruit d'un bien n'appartenant au défunt qu'en nue-propriété, JCP N 1975, I, n° 2694). Cet usufruit successif prendra effet le jour de la cessation de l'usufruit originel puisque l'extinction par consolidation de l'article 617 du Code civil ne produit d'autre effet que d'éteindre l'usufruit initial (M. Iwanesko : L'usufruit successif ou la quasi-fiducie, Droit et Patrimoine 03/1999).

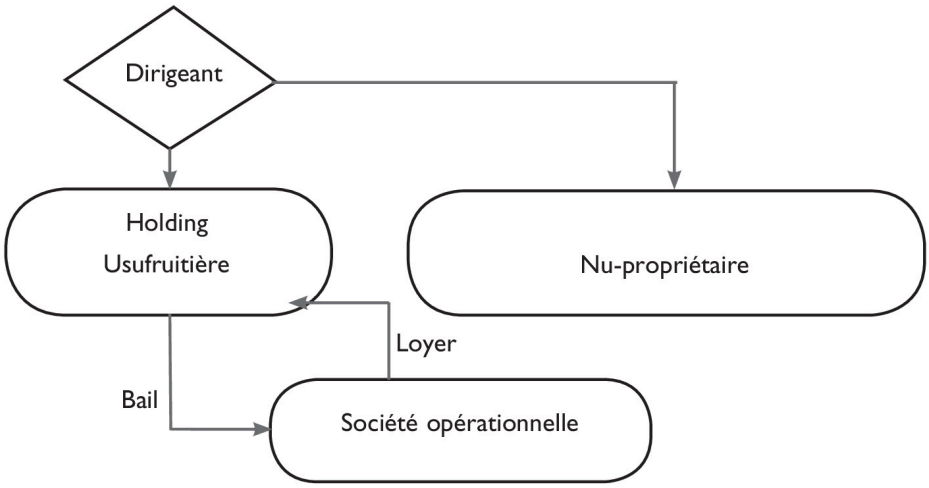
Au terme de l'usufruit acquis par la société opérationnelle, l'usufruit successif constitué sur la tête des parents s'ouvrira et leur permettra de percevoir les revenus de l'immeuble.

Au décès du survivant des parents, l'usufruit successif s'éteindra et les enfants recouvreront la pleine propriété des droits sociaux.

2. Usufruit acquis par la holding, nue-propriété acquise en nom propre ou dans une société civile

534

Lorsque le groupe aura une holding de tête, qu'il s'agisse d'une holding de reprise ou d'une holding patrimoniale, si l'on ne souhaite pas créer de société ad hoc pour détenir l'usufruit, on aura intérêt à localiser l'usufruit dans cette holding. En effet, la société opérationnelle pourra être cédée en dehors de toute opération immobilière. La holding passera alors bail à sa fille.

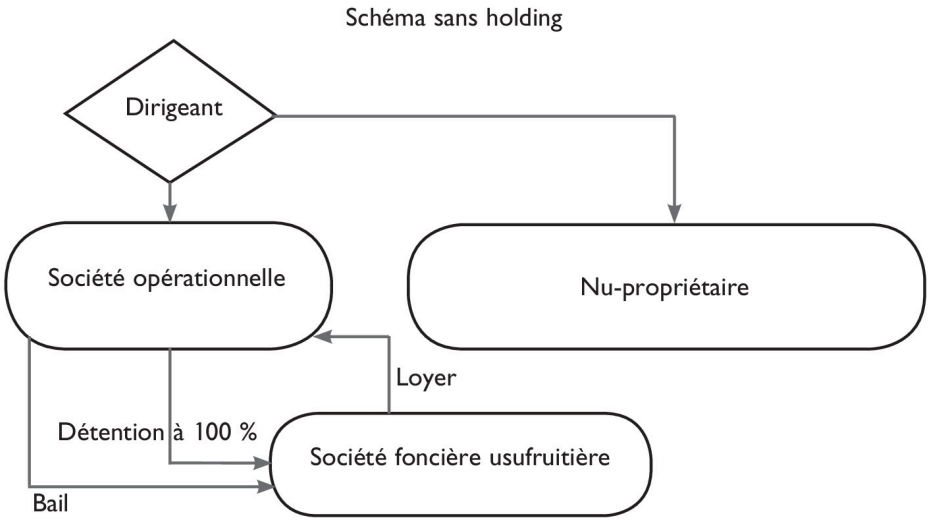


(20190730150406293_10.jpg)

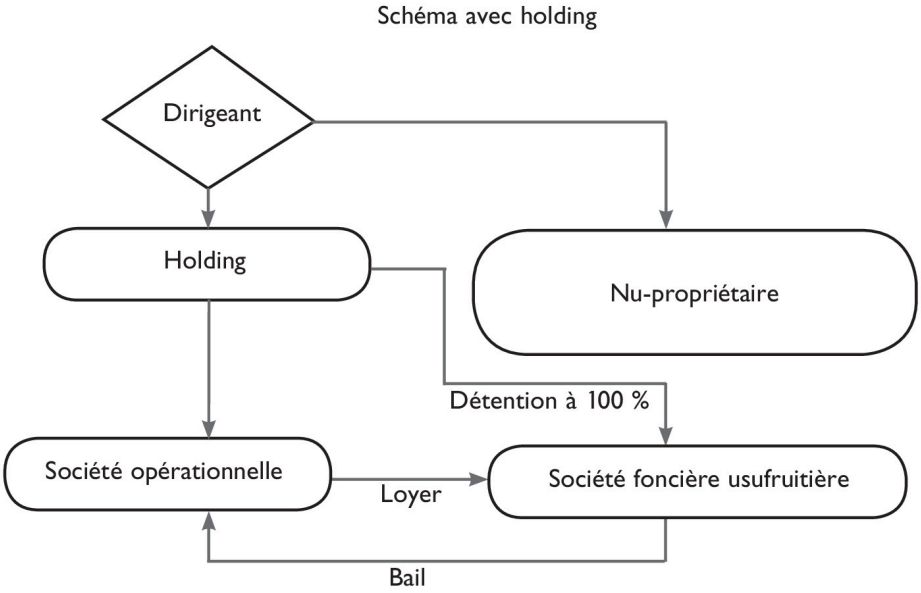
3. Usufruit acquis par une société foncière d'usufruit, filiale de la société opérationnelle ou de la holding, nue-propriété acquise en nom propre ou dans une société civile

535

Ce dernier schéma s'avère un des plus pertinents. Il permet en effet de ne pas affecter de droit réel immobilier à l'actif de la société opérationnelle ou de la holding. Par ailleurs, le dirigeant, souvent enclin patrimonialement à fixer un loyer faible pour ne pas pénaliser sa société d'exploitation, se pénalise à terme car un loyer faible dévalorise son immeuble. Dès lors qu'une centrale de trésorerie aura été mise en place dans le groupe de sociétés, le loyer pourra être fixé à une valeur de marché, sans que la société d'exploitation n'en soit affectée. À terme, la valeur de l'immeuble détenu par le dirigeant sera valorisée à sa valeur de marché.



(20190730150406293_11.jpg)



(20190730150406293_12.jpg)

II. Les relations juridiques entre l'usufruitier et le nu-propriétaire

536

Le droit commun règle la répartition du pouvoir entre l'usufruitier et le nu-propriétaire, mais des aménagements statutaires et conventionnels sont possibles.

A. Les principes fixés par la loi

537

Deux textes réglementent la question :

-l'article 1844 du Code civil d'une part ;

-l'article L. 225-110 du Code de commerce d'autre part.

1. L'article 1844 du Code civil

538

La loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, dite loi SOILIHI a modifié l'article 1844 du Code civil.

Cet article dispose désormais : *« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.*

Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »

Ce texte est codifié au Chapitre I, Livre III, Titre IX du Code civil. Ce chapitre est intitulé : *« Dispositions générales »*. Il constitue le droit commun des sociétés et s'applique à toutes les sociétés pour lesquelles la loi n'a pas prévu de régime dérogatoire.

Sauf stipulation contraire (art. 1844, al. 4), l'usufruitier vote pour l'affectation du bénéfice et le nu-propriétaire vote pour toutes les autres décisions (art. 1844, al. 3).

L'article L. 225-110 du Code de commerce s'applique de manière dérogatoire aux SA et aux SCA (Cf. infra n° 536).

Il ressort de la loi SOILIHI, s'inscrivant dans un processus global de simplification de l'environnement juridique des entreprises, les réformes suivantes :

-Consolidation du droit d'ordre public du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives et consécration législative de ce même droit au profit de l'usufruitier. Ce droit de participer aux décisions collectives s'étend au-delà du simple droit de participer aux assemblées générales. Ainsi, l'usufruitier comme le nu-propriétaire a le droit d'être convoqué aux assemblées, de recevoir les informations préalables, d'y assister, d'exprimer son avis mais aussi de participer aux consultations écrites.

Toutefois, participer ne signifie pas nécessairement voter. Il est donc possible de supprimer, suivant les limites détaillées ci-après, le droit de vote du nu-propriétaire ou de l'usufruitier à condition que son droit de participer aux décisions collectives soit respecté.

-Consécration de la faculté de répartition conventionnelle du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette faculté de répartition conventionnelle permet, en dehors des statuts, aux titulaires de droits sociaux démembrés de conclure un contrat tendant à accroître le droit de vote de l'usufruitier (Cf. infra n° 542). Cette innovation permet une répartition de l'exercice du droit de vote à géométrie variable. Enfin, la loi SOILIHI n'a pas tranché la question débattue de l'attribution de la qualité d'associé à l'usufruitier. Celle-ci a été tranchée par la Cour de cassation qui ne reconnaît pas à l'usufruitier la qualité d'associé (cass. com., avis, 1er déc. 2021, n° 20-15.164 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=20-15164&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/44/52/49/JURITEXT000044524918.xml&date=0002-11-30) : « l'usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d'associé, qui n'appartient qu'au nu-propriétaire » ; cass. civ., 3e ch., 16 févr. 2022, n° 20-15.164 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=20-15164&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/44/52/49/JURITEXT000044524918.xml&date=0002-11-30)).

Point pratique

Pour que le titulaire d'un usufruit de droits sociaux soit reconnu comme associé, il est pertinent de lui attribuer une part sociale en pleine propriété. Cette part sociale lui permettra de bénéficier de tous les droits d'un plein propriétaire au sein de la société mais également d'éviter tous les inconvénients liés à l'absence de qualité d'associé.

Par ailleurs, l'attribution volontaire de la qualité d'associé tant à l'usufruitier qu'au nu-propriétaire, par des stipulations spécifiques des statuts, nous semble devoir être admise ; toutefois, elle n'est, à ce jour, pas totalement certaine.

2. L'article L. 225-110 du Code de commerce

539

Il dispose : *« Le droit de vote attaché à l'action appartient à l'usufruitier dans les AGO et au nu-propriétaire dans les AGE.*

Les copropriétaires d'actions indivises sont représentés aux assemblées générales par l'un d'eux ou par un mandataire unique. En cas de désaccord, le mandataire est désigné en justice à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage. À cet effet, le créancier gagiste dépose, à la demande de son débiteur, les actions qu'il détient en gage, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État.

Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. »

Ce texte, codifié dans le Code de commerce, s'applique aux SA et aux SCA. Il déroge aux principes généraux posés par le Code civil.

Dans ces sociétés, sauf stipulation contraire (art. L. 225-110, al. 4), l'usufruitier vote les décisions relevant de l'AGO et le nu-propriétaire celles relevant de l'AGE (art. L. 225-110, al. 1).

Des clauses statutaires peuvent déroger à cette répartition (c. com., art. L. 225-110, al. 4 : « Les statuts peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa. »).

Cependant, contrairement au droit commun de l'article 1844 du Code civil, il est impossible de déroger conventionnellement (en dehors des statuts) à cette répartition, faute de dispositions analogues à celles figurant au troisième alinéa, in fine, de l'article 1844 du Code civil (Rép. min. Romain Grau n° 40724 : JOAN 11 janv. 2022). En effet, l'article L. 225-110 du Code de commerce forme un dispositif spécial faisant échec à l'application, aux sociétés qui y sont soumises, des dispositions nouvelles de l'article 1844 du Code civil.

B. Les aménagements statutaires et la jurisprudence

540

Les dispositions légales répartissant le droit de vote sont des règles supplétives de la volonté des parties. Les aménagements statutaires des droits de vote sont possibles dans toutes les sociétés (c. civ., art. 1844, al. 4 et c. com., art. L. 225-10 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L225-10&idspad=LEGIARTI000006223521), al. 4), dans les limites suivantes :

1. S'agissant de l'usufruitier

a) L'augmentation de ses droits de vote

541

Le nouvel alinéa 4 de l'article 1844 du Code civil permet aux statuts de déroger au principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour l'affectation des bénéfices, sous réserve de ne pas porter atteinte au droit de ce dernier de participer aux décisions collectives. Dès lors que le nu-propriétaire est convoqué aux assemblées générales, reçoit les informations préalables et a la possibilité de s'exprimer, les statuts peuvent conférer le droit de vote au seul usufruitier, pour l'intégralité des décisions.

Ce nouvel alinéa consacre une jurisprudence constante, selon laquelle les statuts peuvent lui conférer le droit de vote pour toutes les décisions, quel que soit le type de société (cass. com, 4 janvier 1994, BC I n° 10 : « Mais attendu que la clause statutaire selon laquelle l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales quel qu'en soit l'objet, si elle permet à l'usufruitier d'exercer seul le droit de vote en application des dérogations autorisées sur ce point par l'article 1844, alinéa 4, du Code civil… » ; cass. civ., 2e ch., 13 juillet 2005, n° 02-15904 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=02-15904&sp=/juri/cass/global/civile/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050876.xml&date=2005-07-13) : « Attendu que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire… », cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-13185 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=08-13185&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/19/88/28/JURITEXT000019882804.xml&date=2005-07-13) : « Alors que, premièrement, les statuts sont libres de décider que le droit de vote sera dévolu à l'usufruitier en cas de démembrement des parts sociales… »).

Avant l'entrée en vigueur de la loi SOILIHI, la pratique antérieure consistait à insérer dans les statuts une clause permettant à l'usufruitier et au nu-propriétaire de convenir contractuellement des modalités d'exercice du droit de vote afférent aux droits sociaux grevés d'usufruit. L'efficacité de cette pratique dépendait des volontés convergentes de l'usufruitier, du nu-propriétaire et des dirigeants de la société. Ainsi la loi SOILIHI a pris soin de sécuriser juridiquement cette pratique en consacrant la possibilité pour l'usufruitier et le nu-propriétaire de titres sociaux démembrés de convenir conventionnellement que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier (Cf. infra n° 542).

b) La limitation de ses droits de vote

542

Les statuts peuvent limiter les droits de vote de l'usufruitier sous réserve de respecter les deux bornes suivantes :

-Impossibilité de le priver du droit de vote de l'affectation des bénéfices ;

-Impossibilité de le priver de son droit de participer aux décisions collectives.

α) Impossibilité de priver l'usufruitier de son droit de voter l'affectation des bénéfices

543

L'article 1844 du Code civil permet aux statuts de déroger au principe selon lequel le droit de vote appartient au nu-propriétaire sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Lorsque l'article 1844 a été modifié, il s'est posé la question de savoir si les statuts pouvaient priver l'usufruitier de voter à l'assemblée décidant l'affectation des bénéfices.

La rédaction du dernier alinéa de l'article 1844 du Code civil peut s'avérer trompeuse en ce qu'elle autorise une dérogation « aux dispositions de la seconde phrase du troisième alinéa » de cet article, lequel précise notamment que le droit de vote afférent à l'affectation des bénéfices « est réservé à l'usufruitier » ; certains avaient alors envisagé qu'il soit possible de priver l'usufruitier de voter lors des décisions relatives à l'affectation des bénéfices. Toutefois, une telle clause, contraire au droit des biens, serait inefficace en ce qu'elle priverait l'usufruitier des prérogatives essentielles que l'article 578 du Code civil rattache au droit d'usufruit : celles d'user du bien et d'en percevoir les fruits. Dénier à l'usufruitier le droit de voter l'affectation du résultat porterait atteinte à l'essence même de son droit.

Il convient donc de considérer que constitue toujours le droit positif la jurisprudence constante selon laquelle l'usufruitier ne peut être privé du droit d'affecter le résultat, s'agissant d'un droit d'ordre public pour lui (cass. civ, 1re ch., 31 mars 2004, BC I n° 71).

β) Impossibilité de priver l'usufruitier de son droit de participer aux décisions collectives

544

Pour la première fois, l'article 1844 du Code civil consacre explicitement le droit de l'usufruitier de participer aux décisions collectives. L'usufruitier ne peut pas être privé de son droit de participer aux assemblées, de recevoir les informations préalables, de débattre et d'y apporter son avis.

Bien que l'usufruitier n'ait pas la qualité d'associé (Cf. supra n° 535), la Cour de cassation a tempéré sa position dans son avis du 1er décembre 2021 en précisant que l'usufruitier peut *« provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d'avoir une incidence directe sur son droit de jouissance »*.

Par conséquent, il faut retenir que l'usufruitier (i) a le droit de participer aux décisions collectives et (ii) se trouve nécessairement titulaire du droit de vote se rapportant à l'affectation du résultat.

2. S'agissant du nu-propriétaire

a) L'augmentation de ses droits de vote

545

Tous les droits de vote peuvent lui être affectés, quel que soit le type de société, à l'exception du droit d'affecter le résultat, qui relève du pouvoir de l'usufruitier (Cf. supra).

b) La restriction de ses droits de vote

546

Le nu-propriétaire peut être privé de tous les droits de vote, mais, en tant qu'associé, ne peut être privé du droit de participer aux assemblées générales. Il s'agit d'un droit d'ordre public consacré à l'alinéa 3 de l'article 1844 du Code civil : *« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives »*.

Ce droit de participer aux décisions collectives du nu-propriétaire était déjà reconnu par une jurisprudence constante (cass. com. 4 janvier 1994, BC I n° 10 : « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si selon l'article 1844 alinéa 4 du Code civil, il peut être dérogé à l'alinéa 3 du même article qui est relatif au droit de vote..., aucune dérogation n'est prévue concernant le droit des associés et donc du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1 dudit article, la Cour d'appel a violé le texte susvisé... » ; cass. civ., 2e ch., 13 juillet 2005, n° 02-15904 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=02-15904&sp=/juri/cass/global/civile/JURI/TEXT/00/00/07/05/08/JURITEXT000007050876.xml&date=2005-07-13) : « Mais attendu que la clause statutaire selon laquelle l'usufruitier représente valablement le nu-propriétaire pour toutes les décisions sociales quel qu'en soit l'objet, si elle permet à l'usufruitier d'exercer seul le droit de vote en application des dérogations autorisées sur ce point par l'article 1844, alinéa 4, du Code civil, ne peut avoir pour effet de priver le nu-propriétaire du droit de participer aux décisions collectives tel qu'il est prévu à l'alinéa 1 dudit article » ; cass. com., 2 décembre 2008, n° 08-13185 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=COM.&numero=08-13185&sp=/juri/inca/global/commerciale/JURI/TEXT/00/00/19/88/28/JURITEXT000019882804.xml&date=2008-12-02) : « Attendu que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives... »).

C. Les aménagements conventionnels

547

La loi SOILIHI a consacré à l'article 1844 du Code civil la faculté de répartition conventionnelle du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire. Cette faculté permet aux titulaires de droits sociaux démembrés d'organiser conventionnellement une répartition des droits de vote à géométrie variable. Cette nouvelle possibilité permet de rendre plus souples les relations entre usufruitier et nu-propriétaire qui ne peuvent pas ou ne veulent pas faire modifier les statuts sur la répartition des droits.

Le transfert conventionnel ne porte pas sur le droit de vote lui-même, mais uniquement sur son exercice. Ainsi, en présence d'une convention tendant à accroître le droit de vote de l'usufruitier, le nu-propriétaire demeure titulaire du droit de vote (en vertu des statuts), seul l'exercice de ce droit est transféré à l'usufruitier.

Point de vigilance

La lecture des statuts ne suffit plus à connaître qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire exerce le droit de vote. Une convention entre titulaires de droits sociaux démembrés peut aménager l'exercice du droit de vote, tel qu'il est attribué par les statuts et, à défaut, par la loi.

Par la consécration de cette faculté, loi SOILIHI a souhaité sécuriser juridiquement la pratique antérieure consistant à déléguer intégralement le droit de vote du nu-propriétaire à l'usufruitier.

Cette faculté de répartition conventionnelle prend le plus souvent la forme d'un mandat de vote donné par le nu-propriétaire à l'usufruitier.

Il convient de déterminer le domaine de la convention d'exercice du droit de vote, sa nature et son efficacité.

1. Domaine

a) Inapplicabilité aux SA et SCA

548

La faculté d'aménager contractuellement la répartition du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire est prévue par l'article 1844 du Code civil. L'article 1844 du Code civil est un texte de droit commun figurant parmi les dispositions générales du Code civil relatives au droit des sociétés. Ce texte a vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés.

L'article L. 225-110 du Code de commerce forme un dispositif spécial figurant dans les dispositions relatives aux SA au sein du Code de commerce. Il a vocation à s'appliquer aux SA et aux SCA.

Selon une réponse ministérielle (Rép. min. Romain Grau n° 40724 : JOAN 11 janv. 2022), l'article 1844 du Code civil, en ce qu'il accorde la possibilité de transférer conventionnellement certaines décisions à l'usufruitier, est applicable à l'ensemble des sociétés. Toutefois, l'article L. 225-110 du Code de commerce prévoit une règle dérogatoire de répartition du droit de vote. Ainsi la faculté de répartition conventionnelle ne peut être exercée au sein d'une SA ou du SCA car la répartition de ces décisions n'est pas la même que celle prévue dans l'article 1844.

La faculté de répartition conventionnelle du droit de vote entre l'usufruitier et le nu-propriétaire ne peut donc vraisemblablement pas bénéficier aux actionnaires d'une SA et d'une SCA.

b) Champ d'application rationae personae

549

Les parties à la convention sont d'une part l'usufruitier et d'autre part le nu-propriétaire détenant la nue-propriété correspondante. Il peut y avoir autant de conventions que de « couples » usufruitier/nu-propriétaire. Il est également possible de concevoir plusieurs conventions au profit d'un même usufruitier si chaque convention a pour objet différentes catégories de titres de la même société.

En revanche, en cas d'indivision portant sur la nue-propriété, il va de soit que la convention doit être signée par l'ensemble des nus-propriétaires (outre l'usufruitier).

c) Champ d'application rationae materiae

550

Le principe est celui de la liberté contractuelle. La convention peut être conclue par acte authentique ou par acte sous seing privé. Elle peut contenir tout ou partie des titres grevés d'usufruit.

Concernant la durée, la convention peut être conclue pour la durée de l'usufruit. Si l'usufruit de titres sociaux est viager, la convention produira ses effets jusqu'au décès de l'usufruitier. Si l'usufruit est conclu pour une durée fixe (dix ans par exemple), la convention produira ses effets jusqu'au terme de l'usufruit.

Étant précisé que les parties ont la liberté de prévoir une convention de droit de vote pour une durée inférieure à celle de l'usufruit.

2. Nature : un mandat de vote

551

L'article 1843 alinéa 3 du Code civil prévoit que le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier. Le texte n° 790 déposé au Sénat le 4 août 2014 par Monsieur SOILIHI, dans le cadre de l'élaboration de la loi SOILIHI, précise : *« Il s'agirait de prévoir que le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent également participer aux délibérations sur les décisions collectives des associés, mais que le nu-propriétaire a la possibilité de déléguer intégralement son droit de vote à l'usufruitier »*.

Ainsi, l'article 1844 alinéa 3 du Code civil fait référence à la technique de la délégation de vote pour répartir conventionnellement l'exercice droit de vote des titulaires de droits sociaux démembrés.

La délégation est définie par la Doyen Cornu (Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Association Henri Capitant, 12e édition) comme l'opération par laquelle le titulaire d'une fonction en transfère l'exercice à une autre personne. Concernant les titulaires de droits sociaux démembrés, il s'agit de l'opération par laquelle le nu-propriétaire transfère l'exercice du droit de vote à l'usufruitier.

En pratique, la convention opérant une délégation du droit de vote du nu-propriétaire au profit de l'usufruitier prend la forme d'un mandat. Le mandat est l'acte juridique par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Le droit commun du mandat est prévu aux articles 1984 et suivants du Code civil. Le régime du mandat prévoit en outre la libre révocabilité du mandataire (c. civ. art. 2004 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=2004&idspad=LEGIARTI000006445302)).

3. Efficacité du dispositif

a) Opposabilité de la convention à la société

552

La loi ne précise pas le procédé permettant de rendre la convention d'exercice du droit de vote opposable à la société. Ainsi, la convention peut être notifiée à la société par l'usufruitier ou le nu-propriétaire. Pour des questions de preuve, la notification devra être effectuée par LRAR ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

b) Révocation de la convention

553

En application du droit commun du mandat, « le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble » (c. civ. art. 2004 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=2004&idspad=LEGIARTI000006445302)). Cette faculté de révocation du mandat est d'ordre public, le mandant ne peut pas y renoncer mais pourra engager sa responsabilité en cas de révocation d'un mandat stipulé irrévocable (cass. civ., 1re ch., 5 février 2002, n° 99-20.895 (/lien_spad/?base=JURI&orig=REVUE_RF_FH&juridiction=CASS&chambre=CIV.&numero=99-20895&sp=/juri/cass/global/civile/JURI/TEXT/00/00/07/04/49/JURITEXT000007044945.xml&date=2002-02-05)).

D. Les particularités relatives à la détention de l'usufruit de parts sociales

554

Dans le cas qui nous intéresse, la société fille est une société civile relevant de l'impôt sur le revenu. Il ne peut s'agir d'une société relevant de l'IS, faute de quoi il ne serait pas possible de bénéficier du régime mère-fille (CGI art. 145 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=145&idspad=LEGIARTI000051203497) et 216 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006069577&numero=216&idspad=LEGIARTI000048831340)).

La valeur de l'usufruit acquis par la société mère est égale à la valeur actualisée de la trésorerie appréhendable. Les droits de vote ouverts à l'usufruitier ne peuvent donc lui permettre de prendre d'autre décision que celle d'affecter le résultat.

En vertu du droit commun l'usufruitier vote :

-pour l'affectation du résultat dans les sociétés dont les titres sont représentés par des parts sociales (c. civ. art. 1844-5 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006070721&numero=1844-5&idspad=LEGIARTI000006444165)) ;

-dans les AGO dans les sociétés par actions (c. com. art. L. 225-110 (/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000005634379&numero=L225-110&idspad=LEGIARTI000006224896)).

Mais ici, la valeur de l'usufruit ayant été déterminée comme la valeur actualisée de la trésorerie appréhendable, l'usufruitier n'a payé que cette valeur. Il ne doit pas pouvoir appréhender autre chose que la trésorerie disponible.

Dans quelle mesure peut-on restreindre les droits de l'usufruitier ?

Dans un arrêt rendu le 31 mars 2004 (cass. civ., 1re, 31 mars 2004 : BC 2004, I, n° 71 ; A. Viander : L'irréductible droit de vote de l'usufruitier, RJDA 8-9/04, p. 858 ; Th. Revet : Usufruit des droits sociaux, RTD civ. 2004, p. 318), la Cour de cassation a suivi la Cour d'appel de Douai qui avait fondé sa décision sur les principes régissant le droit des biens :

« Attendu qu'en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, les statuts subordonnent à la seule volonté des nus-propriétaires ou autres actionnaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir librement les fruits alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles et que l'article 599 du Code civil interdit au nu-propriétaire de nuire à ces droits ;

Attendu qu'en conséquence, la répartition du droit de vote entre le nu-propriétaire et l'usufruitier, telle qu'elle est prévue dans les statuts de la SCA VH Holding, vide de sa substance l'usufruit ;

Attendu que le statut des droits réels est un statut d'ordre public ; qu'il ne peut, dès lors, être créé d'autres droits réels que ceux énumérés par la loi ;

Attendu que l'article 15, alinéa 2, des statuts doit être annulé en ce qu'en privant l'usufruitier de tout droit de vote il porte atteinte aux droits d'ordre public reconnus à l'usufruitier. »

La Cour de cassation suivant l'avis de l'avocat général M.-A. Lafortune (il est donc proposé à la chambre commerciale de prononcer, sur le fondement du droit des biens et des droits de l'usufruitier, une décision de rejet du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt rendu le 5 juin 2003 par la cour d'appel de Douai) confirme que l'usufruitier ne peut être privé du droit d'affecter le résultat, cette prérogative relevant de l'ordre public : *« Mais attendu qu'ayant retenu que la clause litigieuse, en ne permettant pas à l'usufruitier de voter les décisions concernant les bénéfices, subordonnait à la seule volonté des nus-propriétaires le droit d'user de la chose grevée d'usufruit et d'en percevoir les fruits, alors que l'article 578 du Code civil attache à l'usufruit ces prérogatives essentielles, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, est par suite inopérant. »*

Cette décision doit être approuvée. En effet, le droit de voter les décisions concernant l'affectation des bénéfices constitue un minimum auquel il ne saurait être dérogé sans que la qualité même de l'usufruit ne soit atteinte (Th. Revet : Usufruit des droits sociaux, précité).

Le droit de vote attribué a minima à l'usufruitier doit lui permettre de voter pour ce type de décision.

Mais nous l'avons dit, l'usufruitier ne peut appréhender plus que ce qu'il a payé, à savoir la trésorerie disponible. La clause de droit de vote doit être aménagée dans ce sens dans les SA, car le champ d'application des AGO est beaucoup plus important que la simple affectation du résultat.

Il faut cependant aller plus loin. En effet, l'usufruitier ne doit pas pouvoir affecter le résultat en compte courant en l'absence de trésorerie. Ce faisant, il pourrait prétendre à plus que ce qu'il a réellement payé.

Deux voies sont alors envisageables :

-la première consisterait à ce que les statuts ne permettent de distribuer que la trésorerie disponible, le solde du résultat comptable devant obligatoirement être affecté en réserve. Et la doctrine admet que les statuts d'une société civile peuvent définir le contenu exact que les associés ont entendu donner à la notion de bénéfice (P. Berger : La société civile de portefeuille, Droit et Patrimoine 07/2004) ;

-la seconde emprunte la voie contractuelle. Pour parvenir au résultat souhaité, on stipulera dans l'acte de constitution d'usufruit :

-d'une part, que l'usufruitier ne pourra distribuer que la trésorerie disponible telle qu'elle résultera du bilan arrêté lors de la clôture de l'exercice ;

-d'autre part, que le résultat comptable non appréhendable faute de trésorerie disponible sera obligatoirement affecté en réserve et ne pourra en aucun cas être affecté au compte courant de l'usufruitier. Sauf bien sûr si ces réserves devenaient distribuables en cas de trésorerie suffisante, il pourrait alors les prélever dans la limite de la trésorerie appréhendable.

Afin d'assurer la protection du nu-propriétaire, il sera stipulé que la convention est formée dans les termes de l'article 1134 du Code civil. Par ailleurs l'usufruitier renoncera expressément au bénéfice de l'article 1142 du Code civil, lequel dispose : *« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur »*. En cas de refus par l'usufruitier de satisfaire à ses obligations, le cédant pourra en poursuivre l'exécution forcée par voie judiciaire, voire invoquer la déchéance de l'usufruit sur le fondement de l'article 618 du Code civil.

Droits de reproduction et de diffusion réservés © Groupe Revue Fiduciaire 2026. Usage strictement personnel. L'utilisateur du site reconnaît avoir pris connaissance de la licence de droits d'usage, en accepter et en respecter les dispositions.